

[제 1 문] = 2018 년도 민사소송법 기말고사 제 3 문

甲은 乙을 상대로 대여금반환청구의 소를 제기하였다. 이에 대해 乙은 그 대여금을 이미 변제하였다고 주장하면서 그 증거방법으로 甲명의로 작성되고 甲의 인장이 날인되어 있는 영수증을 제출하였고, 甲이 그 변제사실을 다투자 법원은 변론기일에 위 영수증에 대해 증거결정을 한 후 그에 대한 증거조사를 하였다. 다음의 각 물음에 답하라.

1. 甲이 서증인부와 관련하여 위 영수증에 대해 아는 바가 없다고 다투는 경우, 법원은 어떠한 조치를 취하여야 할 것인가? (10 점)
2. 甲이 서증인부와 관련하여 위 영수증의 성립을 부인하였다. 다음의 각 경우, 법원은 각각 어떤 요건 하에서 '甲이 乙에게 대여하여 준 돈을 돌려받았다는 취지가 기재된 영수증에 대하여' 甲이 진정한 의사로 작성한 것인지 및 그 영수증상의 내용을 사실로 인정할 수 있는지를 각 검토하라.
 - 1) 甲이 乙 제출의 영수증에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장이 아닌 위조된 인장에 의한 것이라고 주장하면서 영수증을 부인한 경우 (15 점)
 - 2) 甲이 위 영수증에 찍혀 현출되어 있는 인영은 자신의 인장에 의한 것이지만 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인한 경우 (15 점)
- 3 위 영수증의 인부절차에서 甲은 乙이 제출한 영수증이 자신이 작성한 것이 분명하여 영수증의 진정성립을 인정하였으나 그 후 소송절차가 불리하게 진행되자 위 영수증에 대해 일부가 변조되었다는 취지의 항변을 제출하였다. 이는 허용되는가? (10 점)

I. 문제의 소재

문서의 진정성립 문제. 민소법 제 357, 358 조의 문제

서증이란 문서를 열람하여 그에 기재된 의미 내용을 증거자료로 하기 위한 증거조사를 말한다. 문서가 증거로 제출된 경우, 그에 대한

증거조사절차로서 먼저 문서에 대한 성립의 인부절차를 진행한다. 이에 대한 상대방의 답변태도로서 성립인정, 침묵, 부인, 부지 등이 있는데 이에 대한 소송절차상의 취급이 각기 다르다.

또한 증명하고자 하는 법률적 행위가 그 문서 자체에 의하여 행하여진 경우의 문서를 처분문서라고 하는데, 예컨대 계약서, 합의서, 약정서 등이 있다. 이러한 처분문서는 보고문서와 달리 그 형식적 증거력이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 실질적 증거력이 당연히 인정된다.

II. 설문 1의 해결 - 자기명의 문서에 대한

부지라고 답변하는 것이 가능한지 여부

자기명으로 된 문서에 대하여 아는 바가 없다고, 즉 부지로 답변하는 것이 가능한가에 대하여 문제가 있다.

본인작성의 문서에 있어서 자기 서명이나 날인이 있는 문서에 대해 '부지'의 답변은 인정될 수 없고 부인 또는 인정을 하여야 한다는 것이 判例의 태도이다.

다만 判例는 그 때에 부지라고 답변하면 그것만으로 증거력을 배척할 것이 아니라, 그 문서의 서명이 그 자신의 것인지 그 이름 아래의 인영이 진정한 것인지의 여부를 석명할 것이고, 만일 그 서명이나 인영까지 부인하는 취지라면 상대방에 입증을 촉구할 것이 아니라고 하였다. 따라서, 사안의 경우처럼 자기명의 작성 문서에 대하여 부지로 답변하는 것은 받아들여 질 수 없다.

III. 설문 2의 해결

1. 사문서의 형식적 증거력의 의의

문서가 거증자가 주장하는 특정인의 의사에 기하여 작성된 것을 문서의 진정성립이라 하고, 진정성립의 문서이면 원칙적으로 형식적 증거력이 있다고 한다.

공문서 이외의 문서를 말하는 사문서의 경우, 사문서의 진정에 대해서는 증거대는 측이 그 성립의 진정을 증명하여야 하지만(제 357 조), 그 문서에 있는 본인 또는 대리인의 서명·날인·무인이

진정한 의사임에 기한 것임을 증명한 때에 한하여 진정한 문서로 추정받는다(제 358 조). 이 때의 추정은 사실상의 추정으로, 반증으로서 작성명의인의 의사인가 의심을 품을 수 있을 사정을 증명하면 진정성립이 깨진다.

사문서는 처분문서와 보고문서로 구분하여야 하는데, 그 구분의 실익은 처분문서의 경우 형식적 증거력이 인정되면 특별한 사정이 없는 한 실질적 증거력이 당연히 인정되지만, 보고문서의 경우 형식적 증거력이 인정된다고 하여도 반드시 실질적 증거력이 인정되는 것은 아니고 법관의 자유심증으로 결정할 문제라는 것에 있다

2. 민소법 제 358 조의 해석론

민소법 제 358 조와 관련하여, 判例는 인영의 진정이 인정되면 날인사실을 부인하는 경우라도 날인의 진정이 사실상 추정되고, 날인의 진정이 인정되면 문서전체의 성립의 진정이 제 358 조에 의해 사실상의 추정된다는 2 단의 추정이론을 인정한다. 따라서 인영의 진정이 인정된 문서의 진정성립에 관하여 상대방이 인장의 도용사실 또는 모용사실을 증명하지 못하는 이상 진정성립은 추정된다.

3. 사문서의 실질적 증거력

이는 어떤 문서가 요증사실을 증명하기에 얼마나 유용한가의 증거가치를 말하는데, 실질적 증거력이 있으려면 문서의 진정성립 즉 형식적 증거력이 있을 것이 전제된다.

앞서 살펴본 바와 같이 처분문서의 경우, 그 진정성립이 인정되는 이상 문언의 객관적 의미가 명확하면 기재 내용대로 법률행위의 존재 및 내용을 인정하여야 한다. 즉, 처분문서의 경우 형식적 증거력이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증거력, 즉 법률행위의 사실이 진실이라는 사실상 추정이 생기고, 법관의 자유심증은 제한된다.

영수증의 형식적 증거력이 추정되므로 甲이 인장의 도용사실을 증명하지 못하면 법원은 특별한 사정이 없는 한 영수증의 실질적 증거력을 인정하여야 한다.

4. 소결

법원은 상대방이 도용사실을 증명하지 못하면 특별한 사정이 없는 이상 영수증에 기재되어 있는 사실 즉 乙이 甲에게 변제한 사실을 인정하여야 한다.

Ⅳ. 문서의 진정성립에 관한 자백 문제

자백의 대상은 원칙적으로 주요사실에 한하고, 간접사실과 보조사실에는 자백이 성립하지 아니한다는 것이 원칙이다. 변론주의가 엄격하게 적용되는 것은 주요사실에 한하기 때문이다.

그러나 判例는 문서의 진정성립에 관한 자백은 보조사실에 관한 것이나 그 취소에 관하여서는 주요사실에 관한 자백취소와 같이 취급하여야 할 것이므로 문서의 진정성립을 인정한 자는 이를 철회할 수 없다고 하고, 이는 문서에 찍힌 인영의 진정함을 인정하였다가 이를 철회하는 경우에도 같다고 하였다. 즉, 법원은 문서의 진정성립에 관한 자백에 구속되어 판결의 기초로 삼아야 한다.

따라서 문서의 진정성립에 관한 자백을 취소하기 위해서는 상대방의 동의를 있거나, 법 제 451 조 1 항 5 호- 자백이 제 3 자의 형사상 처벌할 행위에 의하여 이루어진 때이거나, 법 제 288 조 단서에 의하여 자백이 진실에 반하고 착오로 인한 것임을 증명하여야 한다.

취소하려면 반진실과 착오 두 가지를 아울러 증명하여야 하며, 반진실의 증명만으로 착오에 의한 자백이 추정되지는 않는다. 그러나 判例는 자백이 진실에 반함이 증명된 경우라면 변론전체의 취지만으로 착오로 인한 것임을 인정할 수 있다고 본다.

Ⅴ. 백지문서 문제

날인의 진정이 인정되면 문서전체의 성립의 진정이 제 358 조에 의해 추정되나 이는 사실상 추정을 명문화한 것에 불과하여 이를 깨기 위해서는 반증으로 족하다. 문제는 백지문서임이 증명되면 추정이 깨지는가이다.

判例는 2 단의 추정의 경우에는 어디까지나 먼저 내용 기재가 이루어진 뒤에 인영이 압날된 경우에만 그러한 것이고, 백지보충문서, 즉

작성명의인의 날인만 있고 내용이 백지로 된 문서를 교부받아 후일 다른 사람이 보충한 경우, 그 문서의 진정성립의 추정 배제된다고 하였다. 백지문서의 경우에 위임에 관한 증명책임은 수임인에 있다는 것이다. 따라서 문서제출자는 그 기재내용이 작성명의인으로부터 위임받은 정당한 권원에 의한 것이라는 사실까지 입증하여야 한다고 하였다.

[제 2 문]

甲은 丙으로부터 A 토지를 매수하였는데 乙이 A 토지를 불법으로 점유하고 있다고 주장하면서 乙을 상대로 2010 년 A 토지인도청구의 소를 제기하였다.

1. 乙은 변론절차에서 甲이 A 토지의 소유지인 사실은 인정하지만 자신은 1985 년부터 현재까지 20 년 이상 동안 A 토지를 점유하여 왔기 때문에 취득시효가 완성되어(또는 시효취득하여) 이를 인도할 수 없다고 주장(항변)하였다.

(1) 이 경우 법원은 A 토지의 소유권자를 누구로 확정하여야 하는가?(10 점)

(2) 甲이 乙의 시효취득 사실을 다투는 경우 乙은 시효취득사실을 어떻게(또는 어떤 방법으로) 증명하는 것이 적절한 것인가?(20 점)

2. 甲은 乙의 시효취득 주장에 대하여 乙이 1985 년부터 A 토지를 점유하기 시작한 것은 丙과 임대차계약에 기한 것이었으며, 乙은 임대차계약의 존속기간(2 년)이 경과한 후에도 현재까지 악의로 위 토지를 무단점유하고 있다고 다투었다.

(1) 법원의 증거조사결과 甲의 위 주장이 증명된 경우 법원은 乙의 시효취득 주장에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가?(10 점)

(2) 위 (1)과는 달리 법원이 甲의 위 주장에 대하여 모든 증거조사를 다 하였으나 임대차계약의 존재 여부 및 계약종료 후의 악의의 무단점유사실 여부에 대하여 심증이 형성되지 않았다면 법원은 어떻게 판단하여야 하는가?(10 점)

설문 1 의 (1)항은 선결적 권리관계에 관한 자백의 성립여부를, (2)항은 민법 제 198 조 및 제 197 조 소정의 법률상 추정에 따른 증명책임의 완화 내지 경감의 내용을 묻고 있다. 설문 2 의 (1)항은 설문에서와 같은 사유(타주점유사실)의 증명으로 타주점유의 추정이 깨지는지의 여부를, (2)항은 타주점유의 유무가 진위불명일 경우 그 증명책임은 누가 부담하는 것인지에 관하여 묻고 있다.

Ⅱ. 설문 1 의 해결

1. (1)항의 해결

가. 권리자백 중의 한 유형으로 선결적 법률관계에 관한 자백

소송물의 전제가 되는 권리관계나 법률효과를 인정하는 진술은 권리자백에 해당하여 법원을 구속하는 것이 아니므로, 청구의 객관적 실체가 동일하다고 보여지는 한, 법원은 원고가 청구원인으로 주장하는 실체적 권리관계에 대한 정당한 법률해석에 의하여 판결할 수 있다.

나. 구속력의 유무에 관한 학설 및 判例의 태도
다. 사안에의 적용

2. (2)항의 해결

가. 문제의 소재

민법 제 198 조 및 제 197 조 소정의 법률상 추정에 따른 증명책임의 완화 내지 경감의 내용을 묻고 있다.

나. 시효취득 주장의 성격 - 항변, 증명책임의 소재
피고의 시효취득 주장은 원고의 청구를 배척하기 위한 원고의 주장과 양립가능한 별개의 사실을 주장하는 항변에 해당한다. 특히, 법률요건사실설에 따라 시효취득의 항변은 권리소멸사실로서 취득시효의 완성의 주장과 증명책임은 피고에게 있다.

다. 취득시효주장의 요건사실, 주장증명책임(§245)

사안에서 乙은 이 사건 토지를 시효취득했다고 주장하는 바, 乙은 민법 제 245 조의 요건사실 : 1)20 년간 점유한 사실, 2)계속하여 점유한 사실, 3) 소유의 의사로 평온, 공연하게 점유한 사실을 증명하여야 한다.

I. 문제의 소재

라. 20 년간 점유(§198)

1) 민법 제 198 조는 전후양시에 점유한 사실이 있는 때에는 그 점유는 계속한 것으로 추정한다고 규정하고 있으며 이는 법률상추정이다. 이러한 법률상추정규정에 의해 증명책임을 지는 당사자는 전제사실에 대해서만 증명책임진다는 점에서 증명책임을 완화된 채 추정사실은 증명하지 않아도 되는 불요증사실이다. 반면 상대방은 추정사실이 부존재한다는 것을 증명함으로써 추정을 번복할 수 있는데, 추정사실의 부존재에 대하여 증명책임진다는 의미에서 증명책임을 전환된다.

2) 사안에서 乙은 20 년이상 동안 점유하여 왔다는 사실과 점유를 시작한지 20 년이상이 되는 전후 양시에 각 점유한 사실 또는 각 점유한 적이 있다는 사실만 증명하면 자신의 증명책임을 다한 것이며, 이로 인해 증명책임을 전환되어 甲이 반대사실인 점유중단 사실에 대해 증명책임을 부담한다.

마. 자주공연평온한 점유인정(§197 잠정적 진실)

1) 민법 197 조 제 1 항에서는 점유자는 소유의 의사로 선의 평온 및 공연하게 점유한 것으로 추정한다고 규정하는데 이것은 잠정적 진실로서 이에 대해 다투는 자에게 증명책임을 지우고 있기에 증명책임을 전환을 가져온다.

2) 사안에서 乙은 197 조에 의해 자평공이 추정되므로 증명책임을 甲에게 전환되어 乙의 점유가 타주강포은비의 점유라는 사실을 甲이 증명해야 한다.

Ⅲ. 설문 2 의 해결

1. (1)항의 해결

을이 임대차계약에 기하여 점유하기 시작하였다는 사실(타주점유사실)은 시효취득의 요건사실인 자주점유사실과는 반대되는 반대사실이다. 또한 判例(대판 1997.8.21, 95 다 28625)는 악의의 무단점유사실이 증명되면 자주점유의 추정은 깨지는 것으로 보고 있다.

따라서 법원은 을의 점유가 자주점유가 아니라는 것을 이유로(타주점유라는 이유로) 취득시효항변을 배척하여야 한다.

2. (2)항의 해결

가. 진위불명과 증명책임

증명책임이란, 소송상증명을 요하는 사실의 존부가 확정되지 않을 때(진위불명), 해당 사실을 요건으로 하는 법규의 적용이 부정됨으로써, 법률판단을 받게 되는 당사자 일방의 패소할 위험을 말한다.

나. 사안의 경우

乙의 점유에 대해 민법 197 조에 기해 자주점유가 잠정적 진실로서 추정되며, 이에 대해 甲이 乙의 점유에 소유의 의사가 부존재한다는 사실과 타주점유사실에 관한 증명책임을 부담하게 된다. 하지만 사안에서 소유의 의사가 부존재한다는 사실에 대해 진위불명이 되기에 당해 사실이 존재하지 않는 것이 되고 결국 법원은 乙의 취득시효항변이 인정되므로 원고 甲 패소판결을 선고하여야 한다.

< 2012 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

1. 甲은 乙을 상대로 매매를 원인으로 한 A 부동산에 관한 소유권이전등기 청구의 소를 제기하여 승소판결을 받았다. 그 후 항소심 계속 중에 甲은 乙과의 사이에 乙로부터 A 부동산 대신에 금 1 억원을 지급받기로 하고 계속 중인 소를 취하하기로 하는 내용의 화해계약을 소송 외에서 체결한 다음, 위 소를 취하하였다. 그런데 乙은 위 화해계약에 반하여 위 금 1 억원을 지급하지 않고 있는데, 甲이 그 이유를 확인해 본 결과, 乙은 애시당초부터 위 돈을 지급할 의사나 능력도 없는 상태에서 甲을 속이고 甲과 화해계약을 체결하였음을 확인하게 되었다. 甲은 乙로부터 A 부동산에 관한 소유권이전등기를 넘겨오고 싶은데, 이를 위하여 어떠한 법적 수단을 생각할 수 있는가? (20 점)

절차의 명확성과 안정성의 요청 때문에 민법상의 의사표시의 하자에 관한 규정은 소송행위에 적용되지 않음이 원칙. 다만, 소의 취하와 같은 소송행위가 사기 등 제 3자의 형사상 처벌받을 행위로 인하여 행해 졌을 때, 소송법상 이에 대한 구제방법을 인정하는 것이 일반적인 견해임. 소취하의 무효를 주장하면서 기일지정신청을 하는 방법과 다시 소유권이전등기청구의 소를 제기하는 방법을 생각할 수 있는데, 후자의 경우 재소금지에 해당하는 것은 아닌지의 문제가 있음.

(1) 변론기일지정신청(10 점)

소의 취하가 형사상 처벌할 타인의 행위로 인하여 행해진 경우, 민소법 제 451 조 제 1 항 제 5 호의 규정을 유추 적용하여 그 효력을 부인할 수 있다고 보는 것이 判例와 다수설의 입장임. 이 때 유죄의 확정판결이 필요하다고 하는 입장(判例)과 불필요하다고 보는 입장(다수설)이 대립. 이에 따라 甲은 민소법 제 165 조 제 1 항, 민소규칙 제 67 도 제 1 항에 의거하여 소송종료의 효과를 다투면서 기일지정신청을 할 수 있을 것임. 법원은 기일지정신청에 대하여 변론을 열어 신청사유에 대하여 심리한 뒤, 소의 취하가 무효라고 인정되면 본안에 관한 변론절차를 속행하고 소의 취하가 유효라고 인정되면 소송종료선언을 하게 될 것임.

(2) 소유권이전등기청구의 소제기(10 점)

甲은 본안에 대한 종국판결선고 후 소를 취하해 놓고서 다시 동일한 소(당사자와 소송물이 동일한 소)를 제기하게 되는 것이므로 재소금지에 해당되지 않는가라는 의문이 있을 수 있음. 그러나 후소가 전소와 동일한 소라 할지라도 전소와 권리보호의 이익을 달리할 경우에는 재소금지의 원칙이 부적용된다는 것이 判例 및 통설의 입장. 사안의 경우 乙이 소 취하의 전제조건으로 하였던 금전지급의무를 이행하지 않음으로써 甲, 乙간의 약정은 해제 또는 실효되는 사정변경이 발생하였음을 甲이 주장하면서 재소할 경우 이는 새로운 권리보호의 이익 내지 필요성이 인정된다 할 것임.

[소송상 화해계약]

I. 의의

소송상 화해는 소송계속 중 양쪽 당사자가 소송물인 권리관계의 주장을 서로 양보하여 소송을 종료시키기로 하는 기일에서의 합의이다.

II. 성질

1. 사법행위설

민법상 화해계약(민법 제 731 조)과 **동일**한 것으로 본다. 소송상 화해는 소송계속 중 법관의 면전에서 행하여지고, 화해가 성립되었을 때 법원사무관 등이 조서를 작성하여 이를 확인-공증한다는 점에서만 화해계약과 차이가 있다는 입장이다.

2. 소송행위설 - 判例

소송행위로서 소송법의 원칙에 따라 규율되고 민법상 화해계약에 관한 규정의 적용은 **배제**된다고 본다. 다만 소송행위설을 일관하는 경우 소송상 화해에는 민법상 화해에서와 같이 창설적 효력이 인정될 수 없고, 해제조건을 붙일 수 없으나 判例는 이를 인정하고 있다.

3. 양성설

법원에 대한 관계에서는 화해의 내용에 관하여 진술하고 조서에 기재함으로써 소송이 종료되며 이 점에 있어서는 소송법의 적용을 받지만, 당사자 사이에서는 화해의 내용에 대하여 민법의 적용을 받는다는 견해이다.

III. 기판력

1. 기판력부정설 - 사법행위설, 양성설 일부

법 제 220 조에서 화해조서에 확정판결과 같은 효력을 인정한 것은 소송종료효와 집행력을 인정한 것에 그치고, 기판력까지 인정한 것이라고 볼 수 없다는 견해이다.

2. 무제한기판력설 - 소송행위설(判例)

화해조서에는 확정판결과 마찬가지로 어떠한 경우에도 기판력이 인정되며, 화해의 성립과정의 흠은 그것이 재심사유에 해당되어 준재심절차에

의한 구제를 받는 이외에는 그 무효를 주장할 수 없다고 보는 견해이다.

3. 제한적 기판력설 - 양성설

소송상 화해에서 실체법상 아무런 흠이 없는 경우에만 제한적으로 법 제 220 조에 의하여 기판력이 생기며, 실체법상 흠이 있는 한 기판력은 인정될 수 없다고 보는 견해이다.

IV. 화해의 효력을 다투는 방법

1. 당연무효의 사유로 다투는 경우

화해조서에 확정판결의 당연무효와 같은 사유가 있는 경우(실재하지 않거나 사망한 사람을 당사자로) 등은 무효이다. 당사자 한쪽이 화해조서의 당연무효사유를 주장하며 기일지정신청을 할 수 있다. 이 경우 법원으로는 심리를 한 다음, 무효사유가 존재한다고 인정되지 아니한 때에는 소송종료선언을 하여야 한다(규칙 제 67 조 유추적용).

2. 당연무효 외의 사유로 다투는 경우

무제한 기판력설을 취할 경우, 준재심의 소(제 461 조)에 의하여 효력을 다투는 방법 이외에는 구 무효를 주장할 수 없다.

반면 제한적 기판력설을 취하는 경우에는 제 461 조 준재심은 실체법상 흠이 없을 때에 한하여 활용할 제도로 보고, 실체법상 흠이 있을 때에는 기일지정신청이나 별도로 화해무효확인 소 등으로 그 무효를 주장할 수 있다고 본다.

3. 화해조서상 의무불이행으로 다툴 수 있는지 여부 X

이행하지 아니하여 실효되었다거나, 해제함으로써 실효되었다는 이유로 기일지정신청을 하는 것은 허용되지 않는다.

2. 甲은 乙을 상대로 주위적으로 乙과의 A 물건에 관한 매매계약이 유효함을 전제로 그 매매대금의 지급을 청구하면서, 매매계약이 무효로 판단되는 것에 대비하여 예비적으로 이미 인도한 A 물건의 반환을 구하는 소를 제기하였다. 그런데 법원은 매매대금지급 청구를 기각하는 판결만을 선고하였을 뿐, A 물건 반환청구에 관하여는 아무런

판단을 하지 아니하였다. 이에 대해 甲은 항소를 하지 않은 채 위 제 1 심 판결을 그대로 확정시킨 뒤 다시 별도로 위 매매계약의 무효를 이유로 한 A 물건의 반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

1. 쟁점

예비적 병합에서 주위적 청구를 먼저 판단하지 아니하고 예비적 청구를 먼저 판결한 경우, 주위적 청구를 기각판결을 하고 예비적 청구는 판단하지 않은 경우 누락시킨 청구부분이 판단누락인가 재판누락인가 문제된다.

2. 학설 및 判例

예비적 병합에서 이러한 일부판결은 허용되지 않으므로 이를 전부판결로 보고 다만 판단누락에 준하는 위법이 있다고 보는 판단누락설과 재판누락에 해당하여 그 부분은 원심에 계속 중이고 추가판결의 대상이 된다고 보는 재판누락설이 대립한다.

判例는 주위적 청구를 배척하면서 예비적 청구에 대하여 판단하지 아니하는 판결을 한 경우에는 그 판결에 대한 상소가 제기되면 판단누락된 예비적 청구부분도 상소심으로 이심이 되고 그 부분이 재판의 누락에 해당하여 원심에 계속 중이라고 볼 것은 아니라고 보아 판단누락에 준하여 상소로 다투어야 한다는 입장이다.

3. 사안의 경우

선택적, 예비적 병합의 경우, 병합된 여러개의 청구는 동일한 절차에 불가분적으로 결합되어 있기에 일부판결을 할 수 없다는 것이 통설, 判例입장이다. 따라서 사안에서와 같이 법원이 주위적 청구만을 배척하고 예비적 청구에 대한 판단을 하지 않은 경우 이는 재판의 누락이 아니라 추가판결로 시정할 것이 아니고, 병합의 성질상 하나의 전부판결이라고 볼 것이므로 판단누락에 준하여 상소로 다투어야 한다.

4. 결론

갑이 판단누락한 예비적 청구부분을 간편한 분쟁해결수단인 항소로 다투지 아니하고 이를

그대로 확정시킨 뒤 다시 별소를 제기한 것은 권리보호의 이익이 없어 부적법하게 된다.

3. 甲은 그 소유의 A 토지를 乙에게 임대하였고, 乙은 A 토지 지상에 건물을 신축하여 이를 소유하고 있다. 甲은 임대차계약 기간이 종료되었음을 이유로 乙을 상대로 A 토지 지상에 건립된 건물의 철거 및 A 토지의 인도를 구하는 소를 제기하였는데, 乙은 甲에게 임대차계약 종료에 따른 건물매수청구권을 행사할 수 있었음에도 이를 행사하지 않는 바람에 결국 패소하여 그 판결이 확정되었다. 그 후 乙은 甲을 상대로 건물매수청구권을 행사하면서 그 대금청구를 하는 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

1. 결론 허용된다.

2. 논거

1) 문제의 소재

기판력의 표준시인 사실심 변론종결시 이후에 을이 건물매수청구권을 행사하면서 대금청구의 소를 제기하는 것이 기판력의 실권효 또는 차단효에 의해 금지되는지 문제된다.

2) 학설

취소권 해제권 등의 다른 형성권처럼 실권된다는 실권설, 모든 형성권을 변론종결 후에 행사하면 그 후에 발생한 사유로 보고 실권되지 않는다는 비실권설, 매수청구권이 있음을 알았음에도 행사하지 않는 경우에는 실권되지만 몰랐을 경우에는 실권되지 않는다는 제한설 실권설이 대립한다.

3) 判例 - 비실권설

건물매수청구권을 행사할 수 있음에도 불구하고 행사하지 아니한 채 임차인이 패소하여 그 판결이 확정되었다 하더라도, 확정판결에 의하여 건물 철거가 “집행되지 아니한 이상” 건물매수청구권의 행사가 차단된다고 볼 수 없고 적법한 청구이의사유가 된다고 판시하였다.

4) 검토

생각건대 건물매수청구권은 원고의 청구 자체에 하자가 있다는 것을 주장하는 것이 아니라, 별개

독립의 매매대금채권을 행사한다는 점, 건물매수청구권을 언제 행사할 것인가는 권리자의 자유라고 할 것이라는 점에서 判例입장이 타당하고, 따라서 확정판결에 기하여 건물철거가 집행되지 아니한 이상 대금지급청구의 소는 허용된다.

4. 甲은 乙을 상대로 1,000 만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 이에 대하여 乙은 1,500 만 원의 매매대금채권을 가지고 상계한다는 취지의 항변을 제출하였다. 이 소송에서 상계의 항변이 인정되었고 결국 甲의 청구는 기각되어 그 판결이 확정되었다. 그 후,

(1) 甲이 乙의 채권은 애시 당초부터

부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

(2) 乙이 甲의 채권은 애시 당초부터

부존재하였다고 주장하면서 부당이득반환청구의 소를 제기하였는데 이는 허용되는 것인가? (10 점)

1. 결론

모두 허용되지 않는다.

2. 논거

1) 민소법 제 216 조 제 2 항

피고가 상계항변을 제출하였을 경우에 자동채권의 존부에 대하여 비록 판결의 이유중에서 판단하지만 상계로써 대항한 액수의 한도 내에서는 기판력이 발생한다.

2) 학설

상계항변이 채택된 경우, 기판력이 인정되는 범위에 관하여 현재 자동채권이 소멸되어 존재하지 않는다는 점에 기판력이 생긴다는 견해와 수동채권과 자동채권이 함께 존재하였다가 그것이 상계에 의하여 소멸된다는 점에 기판력이 생긴다는 견해가 대립한다.

3) 부당이득반환청구의 적법성

어느 견해를 취하더라도 원고가 피고의 반대채권이 당초부터 부존재하였다고 주장하거나, 피고가 원고의 소구채권이 상계 이외의 다른 이유로 부존재하였다고 주장하여

부당이득반환청구나 손해배상청구의 후소를 제기할 수 없으므로, 논의의 실익은 없다.

사안 (1)과 (2)의 부당이득반환청구는 모두 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

5. (1) 고의에 의한 명예훼손을 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 전혀 별개의 사실을 이유로 하는 영업방해에 의한 손해배상청구의 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10 점)

허용되지 않는다.

(이유)

고의에 의한 명예훼손을 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 전혀 별개의 사실을 이유로 하는 영업방해에 의한 손해배상청구의 반소를 제기한 경우, 양소의 청구 사이에 관련성이 없고 또한 본소에 대한 방어방법과도 관련성이 없으므로 반소의 요건을 갖추지 못하여 부적법하기 때문이다.

(2) 고의에 의한 상해행위를 원인으로 한 손해배상청구의 본소에 대하여 대여금채권으로 상계를 주장함과 아울러 나머지 대여금의 지급을 구하는 반소를 제기하는 것은 허용되는가? (10 점)

허용되지 않는다

(이유)

반소의 요건 가운데 하나는, 반소가 본소에 대한 방어방법과 관련성이 있어야 하는 것인데 이에 해당하기 위해서는 방어방법이 현실적으로 제출되어야 하고 또한 법률상 허용되는 적법한 것이어야 한다. 따라서 사안에서와 같이 상계금지채권에 기한 원고의 본소청구에 대하여 피고가 상계주장 내지 항변을 하는 것은 민법상 금지되어 있으므로(제 496 조) 이러한 경우 이에 바탕을 둔 반소는 부적법한 것이 되기 때문이다.

6. 甲은 자신의 토지상에 건물을 소유하는 乙에 대하여 소유권에 기한 건물철거 및 토지인도의 소를 제기하고, 이어서 위 건물을 乙로부터

임차하여 사용하고 있는 丙에 대하여 건물철거 및 토지인도의 소를 제기하였는데, 그 후 이 두 사건은 변론이 병합되어 심리되었다.

(1) 丙은 아무런 주장도 하지 아니한 채 변론기일에 출석하지 아니하였고, 乙만이 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립과 존속을 주장한 경우, 이 乙의 주장은 甲과 丙 사이의 소송에 영향을 미치는가? (10 점)

(2) 乙과 丙은 모두 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립과 존속을 주장하였지만, 乙만이 그 증명을 위한 증거신청을 하였고 그에 대한 조사가 행하여진 경우, 이 증거조사의 결과는 甲과 丙 사이의 소송에 영향을 미치는가? (10 점)

사안은 공동소송인 乙과 丙 사이에 소송의 승패가 일률적으로 결정될 필요성이 없는 즉 합일확정이 필수적으로 요청되지 아니하는 통상공동소송이다. 이 경우 공동소송인 독립의 원칙이 적용되어 소송자료와 소송의 진행 및 재판은 모두 통일 되지 않는 상태로 행해지게 되는데, 사안에서는 이를 수정하는 원리(주장공통, 증거공통)를 적용할 수 있을 것인가가 문제됨.

(1) 공동소송인 간에 주장공통의 원칙을 적용할 수 있는가의 문제이다.

의의 및 적용여부

(2) 공동소송인 간에 증거공통의 원칙을 적용할 수 있는가의 문제이다.

의의 및 적용여부

< 2013 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 1] = 2017 년도 연습

甲은 건물인도청구 소송을 제기하여 제 1 심에서 패소하고 항소하였다. 甲은 항소심에서 건물인도청구에 갈음하여 전보(손해)배상청구로 그 청구를 변경하였다가 다시 본래의 청구인 건물인도청구로 청구(소)를 변경하였다. 이 경우 통설, 判例에 따르면 법원은 어떤 조치를 취해야 하는가? (20 점)

청구의 교환적 변경에 대한 법적 성질을 신청구 제기(신소 제기)와 구청구 취하의 결합인 것으로 보는 통설, 判例에 따르면 사안의 경우 손해배상청구는 취하로 소멸되고, 건물인도청구는 본안에 관한 종국판결 선고 후에 취하한 소를 다시 제기한 결과가 되어 재소금지의 원칙(267 조 2 항)에 저촉되어 부적법 각하 되는데, 이는 당사자에게 불의타가 된다(5 점)

따라서 이 경우 법원은 소변경 허가가 앞서 소변경이 교환적 변경인가, 추가적 변경인가의 여부에 대하여 석명권을 발동하여야 할 것이고, 원고가 교환적 변경임을 명시하지 않았다면 추가적 변경으로 보아야 할 것이다.(5 점)

2. 甲은 乙의 주소를 알고 있음에도 불구하고 소재불명으로 속여 공시송달명령을 받아 소송을 진행함으로써 乙이 모르는 사이에 승소판결을 받았고 그 판결은 확정되었다.

(1) 이 경우 乙의 소송법적 구제책을 약술하라(10 점)

(2) 만약 甲이 위 판결에 기하여 강제집행을 실시하여 乙에게 손해가 생긴 경우, 乙은 위 판결의 취소 없이 甲에게 직접 손해배상청구를 할 수 있는지에 관하여 약술하라(10 점).

I. 의의

판결의 편취란 당사자가 악의로 상대방이나 법원을 속여 부당한 내용의 판결을 받는 경우를 말한다. 이를 판결의 부당취득이라고 하며, 이렇게 취득한 판결을 사위판결 내지 편취판결이라고 한다.

II. 구체적 사안 및 소송법상 구제방법 - (1)문

1. 법원을 속여 공시송달 - 11 호, 추후보완상소(송달유효)
2. 성명모용소송 - 3 호, 추후보완상소(송달유효)
3. 참칭대표자에게 적법한 대표권 있는 것으로 알고 그가 판결정본 수령 - 3 호, 추후보완상소(송달유효)

4. 피고 주소 허위 기재하여 판결정본을 원고 측 하수인이 송달받도록 함으로써 자백간주 - 항소(송달무효)

III. 실체법상 구제방법 - (2)문

1. 부당이득반환청구

判例는 일반적으로 편취된 판결에 의한 강제집행의 경우에 그 판결이 재심의 소로 취소되지 않는 한 강제집행에 의한 부당이득이 안 된다는 재심필요설이 判例의 입장이다. 확정판결이 취소되지 않는 한, 기판력에 저촉되어 허용될 수 없기 때문이다.

이에 대하여 사위판결의 경우 재심사유가 없거나 재심기간을 넘겨서 재심에 의한 구제가 불가능한 경우가 많을 뿐만 아니라, 명백히 잘못된 것을 바로 잡기 위하여 두 번의 소송을 강요하는 것은 불합리하다는 재심불요설이 있다.

2. 말소-회복등기청구

피고의 거짓 주소로 소송서류가 송달되어 자백간주로 무변론 원고승소판결을 받아 소유권이전등기나 말소등기가 경로된 경우에는 별소로써 위 등기의 말소나 회복을 구할 수 있다. 항소 제기 없이도 가능하다.

3. 불법행위로 인한 손해배상청구

확정판결에 기한 강제집행이 불법행위로 되는 것은 당사자의 절차적 기본권이 근본적으로 침해된 상태에서 판결이 선고되었거나 확정판결에 재심사유가 정의에 반함이 명백하여 묵과할 수 없는 경우로 한정하여, 불법행위 손해배상청구를 할 수 있으나, 그 외의 경우에는 재심의 소를 제기하여 확정판결을 취소하여야 한다는 제한적 재심불요설이 判例의 입장이다.

3. 甲은 乙을 상대로 고의의 불법행위에 기한 손해배상청구의 소를 제기하였는데, 乙은 이에 대하여 매매대금채권으로 상계를 주장함과 아울러 그 초과 채권의 지급을 구하는 반소를 제기하였다. 이는 허용되는가? (10 점) = 2017 년도 연습

허용되지 않는다 (3 점)

(이유)

반소의 요건 가운데 하나는, 반소가 본소에 대한 방어방법과 관련성이 있어야 하는 것인데 이에 해당하기 위해서는 방어방법이 현실적으로 제출되어야 하고 또한 법률상 허용되는 적법한 것이어야 한다. 따라서 사안에서와 같이 상계금지채권에 기한 원고의 본소청구에 대하여 피고가 상계주장 내지 항변을 하는 것은 민법상 금지되어 있으므로(제 496 조) 이러한 경우 이에 바탕을 둔 반소는 부적법한 것이 되기 때문이다. (7 점)

4. 甲은 을에 대하여 매매대금 1 억원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 “甲이 주장하는 매매계약의 성립 시에 나는 외국에 출장 중이었다”고 진술하였다. = 2017 년도 연습 (1) 乙의 진술은 부인인가, 항변인가? (10 점)

부인 즉 이유부 부인이다.(2 점)

이유부 부인(간접부인)은 상대방의 주장사실과 양립하지 않는 사실을 적극적으로 진술하여 상대방의 주장을 부정하는 것이고, 항변은 원고의 주장사실이 진실임을 전제로 이와 논리적으로 양립할 수 있는 진술로서 차이가 있다.

사안의 경우 乙이 계약 성립시에 외국에 출장 중이었다는 주장 내지 진술(현장에 부재하였다는 진술)은 甲이 주장, 증명책임을 부담하는 계약체결 사실과는 양립되지 않는 별개의 사실을 부가하면서 甲의 주장을 부정하는 것이기 때문에 이유부 부인에 해당한다.(3 점)

(2) 乙의 위 진술에 대하여 甲은 “乙이 그 당시 외국에 출장 중이었다는 사실은 인정한다”고 진술하였다. 甲의 진술은 자백으로서 효력이 생기는가?(20 점)

자백은 당사자가 변론 또는 준비절차에서 상대방의 주장과 일치하고 자기에게 불리한 주요사실의 진술로서 변론주의의 내용 중 하나이다. 재판상의 자백은 법원과 당사자를 구속하며 그

대상은 주요사실의 진술에 한하며, 간접사실과 보조사실에 대해서는 자백이 성립되지 않는다는 것이 통설 判例의 입장이다. 그렇지 않은 경우 자유심증주의에 반하게 된다.

사안의 경우 乙이 그 당시 외국에 출장중이었다는 사실은 甲이 주장하는 계약체결사실의 부존재를 추인케 하는 간접사실에 불과하므로 이를 자백하였다 하더라도 자백으로서의 효력은 발생하지 않는다. 구체적으로 법원은 자백한 사실과 다른 사실을 인정할 수 있고, 甲은 이를 임의로 철회할 수 있다.

5. 甲은 乙을 상대로 을 명의의 소유권이전등기는 통정허위표시로서 무효라고 주장하면서 소유권에 기한 말소등기청구의 소를 제기하여 승소하여 그 판결은 확정되었다. 그런데 선의의 丙이 사실심 변론종결 후에 乙로부터 위 토지를 매수하였고, 乙로부터 丙으로의 소유권이전등기가 경료되었다. 이 경우 甲이 받은 확정판결은 丙에 대하여 그 효력이 미치는가? (30 점) = 2017 년도 연습 중복

I. 서설 - 변론종결 뒤의 승계인

1. 의의

확정판결의 기판력은 당사자는 물론 변론종결 뒤의 승계인에 대해서도 그 효력이 미친다(민법 제 218 조 제 2 항).

변론종결 뒤의 특정승계는 피승계인으로부터 소송물 자체를 승계한 경우에 국한하지 아니하고, 계쟁물을 승계한 경우에도 포함하는데, 이러한 입장을 적격승계설(통판)이라 한다.

2. 승계의 범위

전소 변론종결 뒤 승계인인지 여부에 관해서는 원칙적으로 소송물이론의 입장에 따라 달리 보고 있다.

判例는 구소송물 이론을 따라 원고의 청구권이 물건적 청구권인 경우에는 대세적 효력이 있으므로 피고로부터 계쟁물을 승계한 자는 승계인의 범위에 포함되지만, 채권적 청구권인 경우에는 대인적 효력밖에 없으므로 승계인에 포함되지 않는다 판시한다. 반면, 신이론의 입장에서는 그 청구권이

물권적이나 채권적이나를 불문하고 일률적으로 제 218 조 제 1 항의 승계인에 해당하는 것으로 본다.

Ⅱ. 승계인에 대한 기판력의 작용

1. 문제의 소재

원고가 승소확정판결을 받은 경우 변론종결 뒤에 권리를 취득한 제 3 자가 원고에게 대항할 실체법상 독자적인 권리를 가지는 때에도 법 제 218 조 제 1 항의 승계인에 해당하는지 문제된다.

예컨대 원고가 통정허위표시라고 주장하면서 피고를 상대로 말소등기청구소송을 제기하여 승소확정판결을 받은 경우, 패소한 피고로부터 선의로 위 부동산을 매수하여 소유권이전등기를 마친 사람이 있을 수 있다.

2. 학설 및 判例

신소송물이론의 입장인 형식설은 실체법상 대항할 수 있는 권리를 가진 사람으로서 실체법상 보호될 제 3 자인 경우에도 일단 승계인으로 보아 기판력이 미치도록 하고, 그 후 실체법상 대항할 수 있는 고유의 권리를 주장할 수 있도록 하자는 견해이다.

判例의 입장인 실질설은 구소송물의 입장에서 실체법상 보호될 제 3 자인지 아닌지를 기준으로 승계인의 범위를 결정하여야 한다고 하므로, 실체법상 대항할 수 있는 권리를 가진 제 3 자는 당사자와 동일시할 수 있는 지위에 있다고 할 수 없기 때문에, 기판력이 확장되는 승계인의 범위에서 제외된다고 보는 견해이다.

3. 기판력 받는 승계인의 기준 시점

병이 기판력을 받기 위해서는 승계의 시기가 변론종결 후일 것을 요하는데, 사안과 같이 가등기는 변론종결 전, 이에 기한 본등기는 변론종결 후에 경료 된 경우에 있어서 判例는 본등기 경료시는 기준으로 하여 병을 변론종결후의 승계인으로 본다.

Ⅲ. 결론

형식설에 의하면 갑이 받은 판결은 병에 대하여 기판력은 미치지만 집행력은 미치지 않을 수도 있게 되나 실질설에 의하면 병은 변론종결 후의

승계인에 해당하지 않기 때문에 위 판결의 효력이 미치지 아니한다.

6. 甲은 토지의 소유권에 기하여 그 토지상에 건물을 소유하는 乙을 상대로 건물철거 및 토지인도청구의 소를 제기한 후, 위 건물을 乙로부터 임차하여 거주하고 있는 丙을 상대로 건물 및 토지인도청구의 소를 제기하였는데, 그 후 위 두 사건은 변론이 병합되어 심리되고 있다.
(1) 이 경우 을만이 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립을 주장한 경우, 이 乙의 주장은 丙에게도 그 효력이 미치는가? (15 점)
(2) (1)의 경우와는 달리 乙과 丙이 甲과 乙 사이의 임대차계약의 성립을 주장하였지만, 을만이 그 증명을 위한 증거신청을 하고 그 조사가 행하여진 경우, 이 증거조사결과는 丙에게도 영향을 미치는가? (15 점)

(1) 주장공통의 원칙 (원고 v. 피고)

주요사실은 반드시 주장책임을 지는 당사자가 진술하여야 하는 것은 아니므로, 어느 당사자이든 진술하면 된다. 소송에서 양쪽 당사자 사이에 제출된 소송자료를 통하여 심리가 됨으로써 그 주장의 존재를 인정하더라도 상대방에게 불의의 타격을 줄 우려가 없는 경우에는 이를 재판의 기초로 삼을 수 있다. 이를 주장공통의 원칙이라 한다.

(2) 증거공통의 원칙 (원고 v. 피고)

증거력의 자유평가는 증거제출자에게 유리하게도 또는 불리하게도 평가될 수 있다. 이를 증거공통의 원칙이라 한다. 즉 증거는 어느 당사자에 의하여 제출된 것인지 또는 상대방이 이를 원용하는지 여부에 불구하고 당사자 어느 한쪽에 유리한 사실인정자료로 쓸 수 있다.

필수적 공동소송의 경우에는 공동소송인 가운데 한 사람이 증거를 제출하면 공동소송인 모두에게 효력이 있으므로(법 67 조 제 1 항) 증거공통의 원칙이 당연히 적용된다.

통상공동소송의 경우 특히 법 65 조 전문에 해당하는 통상공동소송의 경우에 증거공통의

원칙이 적용되는지에 관해서는 논의가 있다. 통설은 이 경우에도 증거공통의 원칙이 적용된다고 보고 있는데, 공동소송인 사이에 이해관계가 상반되는 경우까지 확장되는 것은 아니라고 본다.

< 2014 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[설문 1]

<공통의 사실관계>

을은 사업자금이 필요하여 자기 소유의 A 토지를 갑에게 매도하기로 하여, 2011. 7. 14. 매매계약을 체결하여 당일에 갑으로부터 계약금을 지급받고, 중도금 지급일시를 같은 해 8. 14. 잔금 지급일시를 10. 14.로 정하였다. 한편 을의 처 B 는 A 토지 위에 상가건물을 지어 임대수업을 얻는 것이 경제적이라고 생각하여 평소 A 토지의 매도를 반대하였다. 을이 A 토지를 갑에게 매도한 사실을 알게 된 B 는 갑에게 소유권이 넘어가지 않도록 하기 위해서 을이 제 3 자 병에게 A 토지를 매도한 듯이 서류를 위조하여 병 명의로 소유권이전등기를 경료(청주지방법원 충주지원등기와 2011. 8. 20. 접수 4867 호)하게 되었다. 뒤늦게 이 사실을 알게 된 을은 갑에게 사정을 설명하고, 잔금지급기일 전까지 병 명의의 소유권이전등기를 말소해 줄 것을 약속하였다.

1. 갑은 잔금지급기일이 지났음에도 병 명의의 소유권등기가 말소되지 않자 병 명의의 소유권이전등기는 원인무효임을 주장하며, 자신의 을에 대한 소유권이전등기청구권을 보존하기 위하여 을을 대위하여 병을 피고로 소유권이전등기말소등기절차의 이행을 청구하고, 동시에 을을 피고로 해서 자기 앞으로 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하고자 한다. 한편 갑과 을이 매매계약을 체결할 때 “당해 매매계약과 관련하여 발생한 분쟁은 매도인의 주소지를 관할하는 법원이 재판한다.”는 합의를 하였기 때문에, 갑은 을의 주소지 법원인 대전지방법원에 을과 병을 공동피고로 하여 소를 제기하였다.

<참조> A 토지의 소재지: 충북

청주시(청주지방법원 충주지원 관할) / 갑의

주소지: 청주시(청주지방법원 관할) / 을의 주소지:

대전시(대전지방법원 관할) / 병의 주소지:

수원시(수원지방법원 관할)

(1) 대전지방법원에서 진행된 제 1 회 변론기일에 출석한 피고 병은 원고 갑과 피고 을 사이의 관할합의는 갑의 자신에 대한 청구에 그 효력이 미치지 않으며 그 청구에 대한 관할법원은 자신의 주소지 법원인 수원지방법원이라고 주장하면서, 관할위반을 원인으로 하여 수원지방법원으로 소송을 이송하여 줄 것을 신청하였다. 이에 대해 대전지방법원은 피고 병에 대한 청구에 대해서 관할권이 있음을 이유로 병의 소송이송신청에 대해 기각결정을 하였다.

가. 대전지방법원이 병에 대한 청구의 관할권이 있다고 판단한 것은 타당한가? 그 근거는? (15 점)
나. 피고 병은 대전지방법원의 위 기각결정에 대해 불복할 수 있는가? (5 점)

[설문 1-(1)-가]

I. 문제의 소재 (1 점)

갑, 을 간의 관할합의의 효력이 병에게 미치는지 여부 및 관련재판적의 적용 여부가 문제된다.

II. 관할합의의 효력 (6 점)

1. 갑과 을 사이의 관할합의의 유효성

관할합의의 유효요건은 1 심법원의 임의관할에 관한 합의일 것, 합의의 대상이 특정될 것, 관할법원을 특정할 것, 서면에 의할 것 등 (민사소송법 제 29 조)인바, 사안의 경우 갑과 을 사이의 관할합의는 위 요건을 모두 충족하였으므로 유효하다.

2. 관할합의 효력의 주관적 범위

관할합의의 효력은 당사자 및 승계인에게 미친다. 일반승계인의 경우 그 효력이 당연히 미치지만, 특별승계인 중 채권적 승계인의 경우에는 양수인도 변경된 내용의 권리를 양수받았다고 볼 수 있으므로 합의의 효력이 양수인에게 미친다. 반면

물권적 승계인인 경우 물권법정주의(민법 제 185 조) 및 합의된 사항을 공시할 방법이 없음을 근거로 그 합의에 구속되지 아니하는 것으로 봄이 통설과 判例의 입장이다.

3. 소결

갑, 을 간의 관할합의에서 병은 당사자가 아니다. 또한 피고 을로부터 소유권을 이전 받기는 하였으나 이는 물권이므로 본 건 합의의 효력이 병에게 미치지 아니한다. 따라서 갑, 을 간의 관할합의의 효력이 자신에게는 미치지 아니한다는 병의 주장은 타당하다.

Ⅲ. 관련재판적의 적용 여부 (7 점)

1. 서설

갑의 병에 대한 청구의 토지관할법원은 수원지법(민사소송법 제 2 조, 제 3 조)과 청주지법 충주지원(민사소송법 제 21 조, 의무이행지의 특별재판적이 문제될 수 있으나, 判例는 부동산 등기의무의 이행지는 민사소송법 제 21 조의 등기소재지로 보고 있음)이다. 따라서 대전지법은 병에 대한 청구의 토지관할법원이 아니지만, 갑과 을 사이의 관할합의 법원이므로 이 경우 관련재판적의 적용이 긍정되면 병에 대한 관할권을 행사할 수 있다. 한편, 병이 관할위반을 주장하고 있으므로 변론관할이 발생할 여지는 없다.

2. 의의 및 요건

(1) 의의: 원고가 수개의 청구를 병합해서 제소한 경우에 법원이 청구 중 어느 하나에 토지관할권이 있으면, 법정관할권이 없는 나머지 청구도 그 법원에 관할권이 생기는 것을 말한다 (민사소송법 제 25 조).

(2) 요건: 어느 한 청구에 대해 관할권이 있을 것(민사소송법 제 25 조 내지 제 24 조의 규정에 의하여 1 개의 청구에 대하여 관할권을 갖는 법원에 다른 청구를 병합하여 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있으나, 반드시 이에 한정할 필요가 없으며 1 개의 청구에 대해 합의관할이 있는 경우에도 관련재판적을 적용할 수 있다고 본다 (다수설). 대전지법은 합의관할 법원이므로 관련재판적을 적용할 수 있다.

공동소송의 경우 공동소송인 상호간의 청구가 실질적인 관련성이 있을 때(민사소송법 제 65 조 전문) 관련재판적의 적용이 긍정된다(민사소송법 제 25 조 제 2 항). 갑의 을에 대한 청구와 갑의 병에 대한 청구는 동일한 토지에 대한 것으로서 사실상 같은 원인에 기한 것으로 갑의 을, 병에 대한 청구는 상호간에 실질적 관련성이 있다고 볼 수 있으므로, 갑의 병에 대한 청구에 대하여 대전지법이 관할권을 갖게 된다.

Ⅳ. 결론

갑, 을 사이의 관할합의의 효력은 병에게 미치지 않지만, 관련재판적의 적용으로 대전지법이 관할권을 가지므로 대전지법의 판단은 타당하다.

[설문 1-(1)-나]

I. 문제의 소재 (1 점)

관할위반에 의한 소송이송에 관해 당사자에게 신청권이 긍정되어 즉시항고로 불복할 수 있는지가 문제된다.

Ⅱ. 학설 및 判例 (3 점)

유력설은 관할법원에서 재판받을 피고의 이익, 다른 관할원인과의 균형상 당사자에게 이송신청권을 긍정한다.

하지만 判例는 민사소송법 제 34 조 제 1 항에 당사자의 이송신청권이 규정되어 있지 않음을 근거로 관할위반에 의한 이송신청권을 부정한다.

Ⅲ. 소결 (1 점)

判例에 의하면 법원은 병의 이송신청에 대해 재판할 의무가 없으며 또 이송신청기각결정을 하여도 병은 이에 대해 즉시항고할 수 없고 특별항고도 허용되지 않는다. 그러나 유력설에 의하면 즉시항고가 가능하다.

(2) 본론에서 피고 을은 원고 갑과의 매매계약을 해제하고 계약금과 중도금을 반환하였음을 주장하였다. 증거조사 결과 을의 주장대로 갑과 을 사이의 매매계약이 해제되었음이 인정된 경우,

법원은 ① 갑의 병에 대한 청구와 ② 갑의 을에 대한 청구에 대해서 어떠한 판결을 하여야 하는가? (① 12 점, ② 3 점)

I. 문제의 소재 (1 점)

당사자적격 흠결을 이유로 소각하판결을 해야 하는지 아니면 본안판결을 해야 하는지 여부가 문제된다.

II. 갑의 병에 대한 청구 (12 점)

1. 채권자대위소송의 의의 및 법적 성질

(1) 의의 (1 점)

채권자가 채무자에 대한 자신의 채권을 보전하기 위하여 채무자의 제 3 채무자에 대한 채권을 소송으로 행사하는 것을 말한다.

(2) 법적 성질 (5 점)

소송담당설(다수설, 判例)은 채권자와 채무자가 소송수행권을 갖고 있는 병행형 법정소송담당으로 이해하는 반면, 독립한 대위권설은 민법 제 404 조에서 채권자에게 인정된 대위권을 채권자가 스스로 행사하는 것이지 제 3 자소송담당이 아니라고 파악한다.

2. 피보전채권이 존재하지 않는 경우 (5 점)

소송담당설은 피보전채권의 존재는 당사자적격의 기준으로서 소송요건으로 보는 반면, 독립한 대위권설은 피보전채권의 존재는 채권자대위권 행사의 요건인 본안요건으로 본다.

3. 결론 (1 점)

判例의 입장인 소송담당설에 따르면 법원은 당사자적격의 흠결로 소각하판결을 하지만, 독립한 대위권설에 따르면 청구기각판결을 하여야 한다.

III. 갑의 을에 대한 청구 (3 점)

이행의 소에서는 자기에게 이행청구권이 있다고 주장하는 자가 원고적격자이고 이행의무가 있다고 주장되는 자가 피고적격자이다. 본 설문에서 갑은 을에 대해 소유권이전등기청구권이 있다고 주장하여 원고적격은 있지만, 그 청구권의 발생원인인 매매계약이 해제되었으므로 법원은 청구기각판결을 선고한다.

(3) 갑이 을과 병을 공동피고로 한 소송계속 중, 을은 병을 피고로 하여 등기원인의 무효를 주장하며 소유권이전등기말소청구의 소를 별소로 제기하였다. 을이 제기한 후소는 적법한가? (15 점)

I. 문제의 소재 (1 점)

채권자대위소송 계속중 채무자가 제기한 후소가 중복소송으로서 금지되는지 여부가 문제된다.

II. 중복소송금지의 원칙 (11 점)

1. 의의 (1 점)

이미 사건이 계속되어 있을 때는 그와 동일한 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다 (민사소송법 제 259 조)

2. 요건 (10 점) - 전소와 후소의 사건이 동일하여야 한다.

(1) 당사자의 동일성 (9 점)

전소와 후소의 당사자가 다르더라도 전소 확정판결의 기판력이 후소 당사자에게 미치는 경우 당사자의 동일성을 긍정할 수 있다.

가. 소송담당설

소송담당설은 민사소송법 제 218 조 제 3 항을 적용하여 채권자대위소송의 판결의 기판력이 채무자에게 확장될 수 있음을 인정한다. 다수설과 判例도 기판력의 확장에 의해 전소와 후소의 당사자의 동일성을 인정할 수 있다고 한다. 유력설은 채무자가 채권자대위소송의 계속을 알았거나 알 수 있었을 때 채권자가 받은 판결의 기판력이 채무자에게 미친다고 제한적으로 해석하는 判例의 견해를 고려하여, 본 설문의 경우에도 을이 채권자대위소송을 하는 것을 알았거나 알 수 있었을 때 전소와 후소의 당사자의 동일성을 긍정한다.

나. 독립한 대위권설

채권자대위소송은 소송담당이 아니므로 민사소송법 제 218 조를 적용할 수 없으며 기타 대위소송의 판결의 기판력이 채무자에게 확장되는 법적 근거가 없다. 따라서 전소와 후소의 당사자의 동일성을 긍정할 수 없다.

(2) 소송물의 동일성 (1 점)

소송담당설은 대위소송의 소송물과 후소의 소송물은 모두 채무자 을의 병에 대한 말소등기청구권으로 동일하다고 보지만, 독립한 대위권설은 대위소송의 소송물은 채권자대위권이고 후소의 소송물은 말소등기청구권으로 다르다고 본다.

Ⅲ. 결론 (3 점)

判例에 따르면 중복소송을 이유로 을의 후소에 대해 소각하판결을 내려야 한다. 반면 유력설은 을이 대위소송의 계속사실을 알았거나 알 수 있었을 때 중복으로 보아 소각하하지만, 몰랐을 경우 대위소송에 참가할 기회를 주고 각하해야 한다고 한다. 독립한 대위권설은 을의 후소는 적법하며, 채권자대위소송이 변론종결 전이면 대위권행사 요건의 불비로 청구기각하고 변론종결 후이면 후소에 관계없이 존속한다고 본다.

2. 병은 법인이며 법인등기부에 등재되어 있는 대표자는 Z이다. 갑이 병을 상대로 소를 제기하기 전에 병법인은 대표자를 Z에서 Y로 변경하였는데 이 사실이 법인등기부에 등재되지 않았다. 따라서 갑은 병의 대표자를 Z로 생각하여 피고를 병으로 하고 그 대표자를 Z로 하여 소를 제기하였으며, 변론에서 Z도 대표자 변경사실을 갑이나 법원에 알리지 아니한 채 그대로 절차가 진행되어 갑 청구인용판결이 선고되었다. 이 판결은 유효한가? 병 법인이 위 판결의 취소를 구하고자 할 때 그 방법은? (10 점)

I. 문제의 소재 (1 점)

무권대리인의 소송행위인데 상대방이 대리권 있는 것으로 신뢰하고 그 신뢰에 정당한 사유가 있을 경우 표현대리의 법리를 유추적용할 수 있는지 여부가 문제된다.

Ⅱ. 표현대리의 유추적용 여부 (6 점)

적극설은 소송이 실체법상 권리관계를 처분하는 절차임에 비추어 거래행위와 무관한 것이 아니며,

등기를 해태한 법인을 보호하기 위해 절차를 되풀이하도록 함은 공평의 관념에 반함을 이유로 유추적용을 긍정한다.

判例의 입장인 소극설은 실체법상 표현대리의 법리는 거래안전에 이바지하기 위한 규정이기 때문에 절차안정을 중시하는 소송행위에는 적용될 수 없으며, 그 법적 근거로 상법 제 14 조 제 1 항 단서를 들고 있다.

절충설은 기본적으로 소극설의 입장이나, 부실등기 원인이 법인 자신의 태만에 있는 경우 표현대리의 유추적용을 인정한다.

Ⅲ. 취소를 구하는 방법 (3 점)

소극설의 경우 병 법인은 무권대리를 이유로 상소 또는 재심의 소(민사소송법 제 451 조 제 3 항)로써 청구인용판결의 취소를 구할 수 있다.

적극설의 경우 청구인용판결은 유효하며 병 법인은 무권대리를 이유로 상소 또는 재심을 청구할 수 없다.

절충설의 경우 부실등기 원인이 법인의 태만에 기인한 경우 상소 또는 재심을 청구할 수 없다.

[설문 2]

<공통의 사실관계> X는 2009. 3. 24. 횡단보도를 건다가 Y가 운전하던 오토바이에 부딪쳐 부상을 당하였다. X는 Y와의 손해배상금에 관한 합의가 이루어지지 않자, 2009. 6. 1. Y를 피고로 불법행위를 이유로 한 금 4,000 만 원의 지급을 구하는 손해배상청구의 소를 제기하였다.

1. X가 제기한 금 4,000 만 원의 손해배상청구소송의 계속중, X는 2012. 8. 2. 청구금액을 금 7,000 만 원으로 확장하는 청구취지확장신청서를 법원에 제출하였다. 이에 대해 Y는 확장된 금액 부분은 소멸시효가 완성되었다는 항변을 제출하였다. 그런데 X는 처음에 제출한 소장에서 앞으로 시행될 법원의 신체감정결과에 따라 청구금액을 확장할 뜻을 명백히 표시한 바 있었다. 이 경우 법원은 Y의 소멸시효 항변을 받아들여 확장된 금액 부분에 대해 기각할 수 있는가? (15 점)

I. 문제의 소재 (1 점)

일부청구에 관한 소제기의 소멸시효 중단 효력이
잔부청구에 대해서도 인정되는지 문제된다.

II. 일부청구 일반 (6 점)

1. 의의

금전 기타 대체성 있는 물건 등 수량적으로 가분인
급여를 목적으로 하는 특정의 채권을 소송상
분할하여 청구하는 것을 말한다.

2. 일부청구와 잔부청구의 소송물의 동일성

(1) 일부청구 긍정설(다수설, 判例)

일부청구와 잔부청구의 소송물을 달리 보며,
따라서 일부청구에 관한 판결의 기판력이
잔부청구에 미치지 않으므로 잔부청구를 후소로
제기할 수 있다고 본다.

判例도 이 입장을 취하고 있는데, 묵시적
일부청구인 경우 일부청구와 잔부청구의 소송물은
채권 전액으로 동일하다고 보아 일부청구의 판결의
기판력이 잔부청구에 미친다고 한다.

(2) 일부청구 부정설

일부청구와 잔부청구의 소송물은 채권 전액으로
동일하다고 보며, 따라서 일부청구에 관한 판결의
기판력이 잔부청구에 미치므로 잔부청구를 후소로
제기할 수 없다고 본다.

III. 소멸시효 (6 점)

1. 중단 범위

일부청구에 관해 소를 제기하면 일부청구에 대해
소멸시효가 중단된다(민법 제 168 조 제 1 호) 이 때
잔부청구도 소멸시효가 중단되는지는 일부청구와
잔부청구의 소송물의 동일성에 따라 달라진다.

2. 학설 및 判例

(1) 명시적 일부청구 긍정설

일부청구와 잔부청구의 소송물이 다르므로,
일부청구에 대해서만 소를 제기한 경우, 잔부청구는
소멸시효가 중단되지 않는다.

다만 손해배상청구사건에서 앞으로 법원이
선정한 감정인의 감정결과를 보아 청구취지를
확장할 의사를 표명하면서 일부청구를 한 경우,

확장 부분(잔부)도 처음부터 시효중단의 효력에
생긴다고 보는 것이 判例의 입장이다.

(2) 일부청구 부정설

일부청구의 소송물은 채권 전액이므로 소제기시
채권 전액에 대해 소멸시효 중단의 효력이
생긴다고 본다.

IV. 결론 (2 점)

判例에 따르면 확장된 금액 부분도 소멸시효
중단의 효력이 인정되므로 법원은 Y의 소멸시효
항변을 받아들여 이를 기각할 수 없다.

2. X가 Y를 상대로 한 금 4,000 만 원의

손해배상청구에 관한 소는 2010. 6. 1.

청구인용판결로 확정되었다. 그런데 그 뒤 X는 위
교통사고의 후유증으로 2010. 10. 3. 뇌수술을
받기에 이르렀다. 그리하여 X는 2010. 12. 3. Y를
피고로 뇌수술에 따른 치료비 등으로 금 3,000 만
원의 손해배상청구의 소를 제기하였다(후소). X가
제기한 후소는 적법한가? 그 근거는? (10 점)

I. 문제의 소재 (1 점)

후유증으로 확대된 손해에 대한 손해배상청구에
대해서 전소의 기판력이 미치는지 여부가 문제된다.

II. X의 후소의 적법성의 근거 9 점)

1. 일부청구 문제로 보는 견해

전소 변론종결 후에 생긴 치료비 등의 추가청구는
명시적 일부청구 뒤의 잔부청구로 보고 후소의
적법성을 인정한다. (즉 전소 변론종결시까지
지출한 치료비를 손해로 주장한다면 이는 1 개의
채권의 일부에 관해서만 판결을 바란다는 것을
명시하여 제소한 것과 마찬가지로 보아 그
판결확정 뒤 후유증의 악화로 인한 치료비 청구는
잔부청구로 전소 기판력으로 차단되지 않는다.)

2. 기판력의 시적 한계로 보는 견해

전소 당시 예견할 수 없었던 후유증에 의한
손해는 기판력의 표준시까지 배상을 청구할 수
있었던 손해가 아니고, 표준시 뒤의 새로운 사유에

해당되어 후소는 전소 기판력으로 차단되지 않는다고 본다.

3. 별개의 소송물로 보는 견해(다수설, 判例)

전소 계속 중에 당사자에게 그 제출을 기대할 수 없었던 후유증에 따른 손해는 표준시 뒤에 발생한 새로운 사유로 인한 손해로서, 그 소송물은 전소와는 별개의 소송물이라고 보아 전소 후소는 전소 기판력으로 차단되지 않는다고 본다.

Ⅲ. 결론 (1 점)

判例에 따르면 X가 제기한 후소는 전소와 소송물이 다른 것으로서 적법하다.

[설문 3]

갑은 을의 가옥에 대한 신축공사를 하여 그 도급대금으로 6,000 만 원을 청구하였고, 이에 을은 지급일이 1 개월 뒤로 되어 있는 약속어음을 발행하여 갑에게 교부하였다. 1 개월 뒤 갑이 어음금 지급을 청구하였는데, 을은 도급공사에 흠이 있으므로 그 흠이 수리될 때까지 그 지급을 거절한다고 하자 갑은 을을 피고로 어음금지급을 구하는 소를 제기하였다(전소). 법원이 심리한 결과 갑이 제시한 어음에 백지부분이 있어 청구가 기각되었고 그 판결이 확정되었다. 이후 갑은 을을 상대로 대금지급청구의 소를 제기하였다(후소). 이 경우 전소의 소송물과 후소의 소송물이 동일한지 여부를 구소송물이론, 일지설, 이지설에 따라 검토하시오. (15 점)

I. 문제의 소재

어음금청구를 기각한 판결이 확정된 후, 원인채권의 지급을 구하는 소가 제기된 경우, 후소법원은 전소법원의 판단에 구속되는가가 문제된다.

Ⅱ. 기판력의 발생여부

판결의 기판력은 판결주문에 포함된 소송물인 법률관계의 존부에 대한 판단의 결론에 대해서 발생하고, 판결이유에서 판단된 사실인정, 항변, 선결적 법률관계 등에는 발생하지 않는다. 따라서

전소의 판단중 ‘약속어음금 청구권이 부존재한다’는 판단에 기판력이 발생하고, ‘공사대금채권의 존부’는 선결적 법률관계에 해당하는 판결이유 중의 판단으로서 기판력이 발생하지 않는다.

Ⅲ. 기판력의 작용

1. 기판력의 발생범위

기판력은 전소 소송물이 후소의 소송물과 동일하거나 전소의 소송물에 관한 판단이 후소와 선결관계 또는 모순관계에 있을 때 작용한다.

2. 학설

원인채권청구소송과 어음금청구소송의 소송물의 이동

소송물이론 중 구소송물이론인 判例는 양 청구권은 실체법상의 별개의 권리에 해당하기 때문에 별개의 소송물이라고 보고 신소송물이론 중 이지설은 사실관계가 다르기 때문에 별개의 소송물이라고 보나, 반면 일지설은 청구취지가 동일하다는 이유로 동일한 소송물로 파악한다.

3. 사안의 경우

구소송물이론 및 이지설에 의하면 전소의 소송물은 약속어음금 청구권의 존부이고 후소의 소송물은 대금 청구권의 존부로서 소송물이 다르고 전소가 후소와 선결관계나 모순관계에 있지도 않다. 따라서 전소판결의 기판력은 후소에 미치지 않는다.

4. 전소판결의 후소에 대한 구속력 여부

(1) 문제점

전소에서의 소송물의 존부를 판단함에 있어 전제가 되는 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 기판력이 발생하지 않는다는 원칙을 그대로 관철할 경우 전소에서도 후소에서 서로 모순저촉되는 판결이 나올 수 있기 때문에 그 방지를 위한 이론들이 전개되어 있다.

(2) 학설

전소에서의 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 일정한 구속력을 인정할 필요가 있다는 견지에서 일본의 쟁점효이론, 의미관련론, 경제적가치동일성론, 신의칙설(선행행위와 모순되는 거동금지) 등이 대두되어 있다.

(3) 判例

확정된 민사, 형사판결에서 인정된 사실은 유력한 증거가 되므로 합리적 이유의 설시 없이 배척할 수 없고, 특히 두 개의 민사소송의 당사자가 같고 분쟁의 기초사실이 같은 경우에는 전소의 판단이 후소에 유력한 증거자료로서의 효력, 즉 증명효가 생긴다. [2008 다 92312]

Ⅲ. 결론

判例의 증명효 이론에 따르면 법원은 특별한 사정이 없는 이상 대금 6,000 만 원의 변제사실을 인정하여 갑의 청구를 배척하여야 할 것이다.

< 2015 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 1]

갑은 을을 상대로 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기하여 승소판결이 확정되었고 위 확정판결을 집행권원으로 하여 을에 대하여 강제집행을 신청하였다. 그러자 을은 위 매매대금청구소송에서 갑에 대한 손해배상채권이 있었고 또한 이를 이유로 상계항변을 할 수 있었음에도 불구하고 위 판결확정 후에 비로소 상계하였다고 주장하면서 갑을 상대로 청구이의의 소를 제기하였다. 을이 제기한 위 소는 이유 있는 것으로 인용될 것인가? (20 점).

I. 문제의 소재

변론종결 전에 상계적상이 있었음에도 불구하고 상계권을 행사하지 않은 경우, 후에 상계권을 행사하면서 청구이의의 소를 제기할 수 있는지 문제된다.

Ⅱ. 기판력의 시적범위

1. 개념

종국판결은 사실심 변론종결시까지 제출된 주장사실 및 증거자료를 기초로 하므로 확정판결의 표준시는 사실심 변론종결시이다. 기판력은 표준시 현재의 권리관계의 존부의 판단에만 생기므로,

표준시 이전은 물론 표준시 이후의 권리관계를 확정하는 것은 아니다.

2. 실권효

기판력의 소극적 작용에 기한 효력을 실권효 내지 차단효라고 한다.

당사자는 전소의 표준시 이전에 존재하였으나 그 때까지 제출하지 않은 공격방어방법의 제출권을 잃게 된다.

- 소유권확인소송에서 패소한 원고가 표준시 전에 주장할 수 있었던 다른 취득원인 사실로써 후소로 같은 소를 제기하는 것은 기판력에 저촉된다.

- 전소에서 원고가 승소한 경우 패소한 피고는 전소 변론종결 전에 발생한 변제-면제-소멸시효완성 등 채무의 소멸사유를 들어 다투는 것은 기판력에 저촉된다.

Ⅲ. 표준시 뒤의 형성권 행사 - 상계권의 행사

1. 전소 변론종결 뒤 상계권 행사와 청구이의의 소 제기 여부

채무자가 집행권원인 확정판결의 변론종결 전에 상계적상에 있는 채권을 가지고 있었다 하더라도 확정판결의 변론종결 뒤에 이르러 비로소 상계의 의사표시를 한 때에는 청구이의의 소에 관한 민사집행법 제 44 조 제 2 항에서 규정하는 '이의는 그 이유가 변론이 종결된 뒤에 생긴 것'에 해당한다.

이 경우 당사자가 집행권원인 확정판결의 변론종결 전에 상계권의 존재를 알았는지 몰랐는지 여부에 관계 없이 적법한 청구이의사유가 된다.

2. 학설

비실권설은 상계권은 물론 취소권, 해제권까지 모든 형성권을 변론종결 후에 행사하면 그 후에 발생한 사유로 보고 실권되지 않는다는 견해이고, 상계권비실권설은 취소권, 해제권 등 다른 형성권은 실권되지만 상계권의 존부를 알았든 몰랐든 변론종결후의 사유로서 실권하지 않는다는 견해이다. 또한 제한적 상계실권설은 상계권이 있음을 알면서도 전에 이를 행사하지 않은 경우에는 실권이 된다고 본다.

3. 判例

判例는 상계권비실권설의 입장에서 변론종결한 뒤의 다른 형서권 행사는 원칙적으로 기판력에 저촉되어 실권되지만 상계권만은 예외적으로 실권되지 않는다고 본다.

4. 검토

생각건대, 상계는 원고 청구자체에 하자가 있다는 주장을 하는 것이 아니라 별개독립의 자동채권을 행사한다는 점, 이를 허용하지 않는다는 것은 피고에게 지나치게 가혹하다는 점에서 判例가 타당하다.

[문제 3]

을은 갑을 상대로 을 소유의 토지에 관한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 갑의 주소를 알고 있음에도 불구하고 갑이 마치 행방불명된 자인 것처럼 허위의 주소를 기재하여 법원으로부터 공시송달명령을 받아 낸 다음, 제 3자로 하여금 자신이 갑 소유의 토지를 매수한 것이라는 취지의 허위의 증언을 하게 함과 아울러 위조된 매매계약서 등을 증거로 제출하여 승소판결을 받았다. 그 후 이 판결은 공시송달의 방법에 의하여 확정되었고 을은 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다.

1. 그 후 위와 같은 사실을 알게 된 갑은 을을 상대로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의 말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 이 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20 점)

1. 결론 (5 점)

법원은 甲의 청구를 기각하거나 甲의 소를 각하하는 판결을 하여야 한다. 또는 甲의 청구를 배척하는 판결을 하여야 한다.

2. 이유 (15 점)

乙은 공시송달의 요건이 구비되어 있지 않음에도 불구하고 마치 그 요건이 구비된 것처럼 법원을 기망하여 공시송달명령을 받아 甲이 모르는 사이에

승소판결을 받아 乙 명의로 소유권이전등기를 마쳤는데, 이와 같이 공시송달에 의한 판결편취의 경우에는 공시송달에 의한 판결정본의 송달이 유효한 것으로 보는 것이 통설, 判例의 입장이다. 따라서 乙과 甲 사이의 전소에 관한 1심법원의 판결은 적법하게 확정된 것으로 보아야 하고, 이 경우 갑은 항소의 추후보완(추완항소)의 방법이나 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 11 호 소정의 재심사유를 주장하여 재심신청의 방법으로 위 확정판결의 효력을 다룰 수 있을 뿐이다(통설, 判例).

甲은 위와 같은 방법으로 위 확정판결의 효력을 다투지 아니한 채, 전소에 확정된 법률관계와 모순 또는 반대되는 권리관계를 후소에서 소송물로 주장하고 있는데 이는 전소 판결의 기판력에 저촉되는 것이다. 즉 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 확정판결에 의하여 乙 명의의 이전등기가 마쳐진 경우에 甲이 다시 그것이 원인무효임 내세워 乙을 상대로 그 말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하는 것은 이미 확정된 乙의 이전등기청구권을 부인하는 것이어서 기판력에 저촉되는 것이다. 따라서 법원은 甲의 청구를 기각하거나(기판력의 본질에 관한 모순금지설의 입장) 소송요건의 흠결을 이유로 甲의 소를 각하(반복금지설의 입장)하여야 한다.

2.

1. 결론 (3 점)

갑의 소는 부적법한 것이다. 따라서 법원은 부적법 각하판결을 하여야 한다.

2. 이유 (7 점)

판례는 소유권이전등기의 말소등기청구소송과 진정명의회복을 위한 소유권이전등기청구소송은 형식상 내지 명목상으로는 청구취지가 다름에도 불구하고 동일한 소송물로 보고 있다.

소유권이전등기 말소등기청구소송에서 패소 확정된 자가 후소로써 진정한 등기명의회복(진정명의회복)을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 제기한 경우, “후소인

진정한 등기명의회복의 이전등기청구와 전소인 말소등기청구가 모두 진정한 소유자의 등기명의회복을 위한 것으로 실질적으로 그 목적이 같고 두 청구권 모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 법적 근거 내지 성질이 같아 결국 소송물이 동일하므로 후소는 전소의 기판력에 저촉되는 것"이라고 판시하고 있다. (99 다 37894) 따라서 갑이 제기한 후소는 기판력에 저촉되는 부적법한 것으로서 각하되어야 한다.

[문제 4]

1. 서론 (3 점)

갑과 병, 정, 무가 공동원고가 되어 제기한 소송이 통상 공동소송인가 아니면 필수적 공동소송인가에 따라 그 결론이 달라진다. 判例는 이 경우 통상공동소송으로 본다. 따라서 공동소송인 독립의 원칙이 적용된다.

2. 공동소송인 독립의 원칙의 개념 및 내용 (15 점)

통상 공동소송의 경우 공동소송인 독립의 원칙에 따라 공동소송인 1 인의 소송행위는 유리, 불리를 불문하고 원칙으로 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 아니하고(소송자료의 불통일), 공동소송인 중 1 인에 관한 사항은 다른 공동소송인에게 영향이 없다(소송진행의 불통일).

사안의 경우 갑과 병, 정, 무의 공동소송은 통상 공동소송에 해당하므로 갑만이 제기한 항소는 다른 공동소송인에 대하여는 영향이 없고, 항소기간 역시 각 공동소송인에 대하여 개별적으로 진행된 결과, 갑 이외의 나머지 공동소송인에 대한 관계에서는 항소기간 도과로 분리 확정된 것으로 취급된다.

만약 필수적 공동소송으로 볼 경우에는 합일확정의 요청 때문에 갑만이 항소를 제기하였다 하더라도 이는 민소법 제 67 조 제 1 항에 의하여 전원에 대하여 판결의 확정이 차단되고 전소송이 항소심에 이르게 되므로, 항소심에서 갑만을 항소인으로 취급하여 그 절차를 진행하고 그 항소를 기각하는 판결을 선고한 것은 민소법 제 67 조 제 1 항을 위반한 위법한 판결이 된다.

3. 사안의 해결 (2 점)

따라서 항소심에서 갑만을 항소인으로 취급하여 소송을 진행한 다음 그 항소를 기각하는 판결을 선고하는 것은 적법한 것이다.

< 2016 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[기초적 사실관계]

乙은 전기-전자제품의 제조업자인 甲과의 사이에 甲이 제조한 물품을 공급받기로 하는 총판대리점 계약을 체결하였는데, 乙은 甲에게 물품대금을 지급함에 있어 그 중 일부는 현금으로 지급하고 그 나머지는 6 개월 후에 만기가 도래하는 약속어음을 발행한 후 만기에 은행어음 계좌에 그 대금을 입금하는 방식으로 결제하여 왔다.

[제 1 문의 1]

甲은 乙로부터 물품대금 지급과 관련하여 발행-교부받은 액면금 5 천만 원의 약속어음에 관한 지급이 거절되자 乙을 상대로 위 어음금 5 천만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데, 법원은 이에 대하여 5 천만 원의 물품대금채권의 부존재를 이유로 甲의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 이는 그대로 확정되었다. 그런데 그 후 甲은 乙을 상대로 위 물품대금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 법원은 이에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (30 점)

I. 문제의 소재

원인채권의 부존재를 이유로 어음금청구를 기각한 판결이 확정된 후, 원인채권의 지급을 구하는 소가 제기된 경우, 후소법원은 전소법원의 판단에 구속되는가가 문제된다.

II. 기판력의 발생여부

판결의 기판력은 판결주문에 포함된 소송물인 법률관계의 존부에 대한 판단의 결론에 대해서 발생하고, 판결이유에서 판단된 사실인정, 항변, 선결적 법률관계 등에는 발생하지 않는다. 따라서 전소의 판단중 '약속어음금 청구권이 부존재한다'는

판단에 기판력이 발생하고, '물품대금채권의 부존재'라는 선결적 법률관계라는 판결이유 중의 판단으로서 기판력이 발생하지 않는다.

Ⅲ. 기판력의 작용

1. 기판력의 발생범위

기판력은 전소 소송물이 후소의 소송물과 동일하거나 전소의 소송물에 관한 판단이 후소와 선결관계 또는 모순관계에 있을 때 작용한다.

2. 학설

원인채권청구소송과 어음금청구소송의 소송물의 이동

소송물이론 중 구소송물이론인 判例는 양 청구권은 실체법상의 별개의 권리에 해당하기 때문에 별개의 소송물이라 보고, 신소송물이론 중 이지설은 사실관계가 다르기 때문에 별개의 소송물이라고 보나, 반면 일지설은 청구취지가 동일하다는 이유로 동일한 소송물로 파악한다.

3. 사안의 경우

구소송물이론 및 이지설에 의하면 전소의 소송물은 약속어음금 청구권의 존부이고 후소의 소송물은 물품대금 채권의 존부로서 소송물이 다르고 전소가 후소와 선결관계나 모순관계에 있지도 않다. 따라서 전소판결의 기판력은 후소에 미치지 않는다.

4. 전소판결의 후소에 대한 구속력 여부

(1) 문제점

전소에서의 소송물의 존부를 판단함에 있어 전제가 되는 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 기판력이 발생하지 않는다는 원칙을 그대로 관철할 경우 전소에서와 후소에서 서로 모순저촉되는 판결이 나올 수 있기 때문에 그 방지를 위한 이론들이 전개되어 있다.

(2) 학설

전소에서의 선결적 법률관계에 대한 판단에 대하여는 일정한 구속력을 인정할 필요가 있다는 견지에서 일본의 쟁점효이론, 의미관련론, 경제적가치동일성론, 신의칙설(선행행위와 모순되는 거동금지) 등이 대두되어 있다.

(3) 判例

확정된 민사, 형사판결에서 인정된 사실은 유력한 증거가 되므로 합리적 이유의 설시 없이 배척할 수 없고, 특히 두 개의 민사소송의 당사자가 같고 분쟁의 기초사실이 같은 경우에는 전소의 판단이 후소에 유력한 증거자료로서의 효력, 즉 증명효가 생긴다. [2008 다 92312]

Ⅲ. 결론

判例의 증명효 이론에 따르면 법원은 특별한 사정이 없는 이상 물품대금채권의 부존재사실을 인정하여 갑의 청구를 배척하여야 할 것이다.

[추가된 사실관계]

乙의 총판대리점은 사업부진으로 인하여 2015. 9. 30. 甲으로부터의 물품수령을 마지막으로 문을 닫게 되었는데, 甲은 乙에게 마지막으로 물품을 공급한 당일 그 대금지급과 관련하여 乙로부터 만기가 2016. 6. 30.로 된 액면금 3억 원의 약속어음을 발행-교부받은 다음, 만기가 도래하기 전 丙에게 위 어음을 배서양도하였고, 丙이 만기가 도래한 후 乙에게 위 어음을 지급제시하였으나, 그 지급이 거절되자 丙은 乙을 상대로 위 어음금 3억 원의 지급을 구하는 소송을 제기하면서 그 증거방법으로 乙이 발행한 위 어음을 제출하였다.

[제 1 문의 2]

위 어음에 대한 증거조사절차에서 乙은 위 어음상의 인영은 자신의 인장에 의한 것임이 분명하지만(인영부분 인정), 자신은 스스로 날인한 적이 없다고 부인하였고(위조항변), 丙은 이에 대하여 다투었다. 법원이 심리한 결과, 乙이 주장한 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우와 乙의 주장사실(위조사실)이 진실인 것으로 밝혀진 각각의 경우에 있어서 법원은 어음의 형식적 증거력에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가?

(20 점)

1. 어음(사문서)의 형식적 증거력(진정성립)의 의의 (3 점)

2. 사문서가 증거로 제출된 경우 거증자가 그 성립의 진정을 증명하여야 하지만(민소법 제 357 조) 그 문서에 본인 또는 대리인의 서명-날인-무인이 그의 진정한 의사에 기한 것임을 증명한 때에는 진정한 문서로서 추정을 받는다(민소법 제 358 조). (2 점)

3. 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우에 있어서 어음의 형식적 증거력 (8 점)

문서에의 서명-날인사실이 증명된 것은 아니지만 작성명의인의 인영이 그 사람의 도장에 의하여 현출된 것이라는 사실이 인정되면(인영부분 인정) 그 날인행위가 그 사람의 의사에 기하여 행해진 것이라고 사실상 추정되고, 일단 날인행위의 진정이 추정되면 그 문서 전체의 진정성립이 추정된다(이른바 2 단계 추정). 따라서 사례에 있어 어음의 위조사실의 여부가 밝혀지지 아니한 경우, 즉 을이 인장의 도용사실이나 강박에 의한 날인사실 등에 관한 증명을 하지 못한 이상, 법원은 2 단계 추정에 따라 어음의 형식적 증거력을 인정하여야 한다.

4. 을의 주장사실이 진실한 것으로 밝혀진 경우에 있어서 어음의 형식적 증거력 (7 점)

문서상의 날인이 그 작성명의인의 인영임이 틀림 없으나 그 작성명의인이 아닌 제 3 자가 날인한 것으로 밝혀진 경우에는 진정성립의 추정이 깨진다. 따라서 거증자인 정이 제 3 자에게 위 약속어음의 작성에 관한 권한이 있었음을 증명하지 못하는 이상 법원은 어음의 형식적 증거력을 인정하여서는 안 된다.

[제 2 문]

법원은 갑이 을을 상대로 제기한 위 소송에서 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 2016. 1. 6. 그대로 확정되었는데, 을은 그 후인 2016. 1. 25. A 건물에 관하여 위 가등기에 기한 본등기를 병 명의로 경료하여 주었다. 갑은 을에 대한 승소확정판결을 가지고 A 건물을 철거할 수 있는가? (20 점)

1. 기판력의 주관적 범위에 관한 문제로 병이 변론종결 후의 승계인에 해당하는지 여부가 문제된다.

변론종결 후 소송물인 권리관계 자체를 승계한 자는 아니나, 계쟁물에 관한 당사자적격을 이전받은 자도 승계인에 포함된다고 보는 것이 일반적이다. (3 점)

2. 다만, 소송물이론 중 구이론(判例)은 원고의 청구가 대세효가 있는 물권적 청구권에 기한 것인 경우와 대인적 효력밖에 없는 채권적 청구권에 기한 것인 경우를 구분하여, 전자의 경우에 있어서 변론종결 후 계쟁물을 양수한 자는 민소법 제 218 조 제 1 항 소정의 승계인에 해당되어 기판력이 미치지만, 후자의 경우에 있어서 계쟁물을 양수한 자는 위 승계인에 해당되지 않아 기판력이 미치지 않는 것으로 본다. 반면 신이론은 원고의 청구를 위와 같이 구분하지 않고서 변론종결 후 계쟁물을 양수한 자를 모두 위 승계인에 해당하는 것으로 본다. (7 점)

3. 병이 기판력을 받기 위해서는 승계의 시기가 변론종결 후일 것을 요하는데, 통설과 判例는 사안과 같이 가등기는 변론종결 전, 이에 기한 본등기는 변론종결 후에 경료된 경우에 있어서 본등기 경료시를 기준으로 하여 병을 변론종결 후의 승계인으로 보고 있다. (92 다 10883) (5 점)

4. 병은 변론종결 후의 승계인으로서 갑은 을에 대한 승소판결문에 기하여 승계집행문을 부여 받아 병 소유 건물인 A 건물을 철거할 수 있다. (5 점)

[제 3 문]

갑은 을이 운전하던 택시를 타고 가던 중, 그택시가 그 앞에 진행하던 자동차와 충돌하는 바람에 중상을 입고 병원에 입원하여 치료를 받고 있던 중, 을을 상대로 손해배상청구소송을 제기하였다.

[제 3-1 문]

갑은 위 소송에서 을이 앞차를 보고 제동을 하였으나 과속으로 달린 탓으로 택시가 정차하지 않고 밀리면서 앞차를 들이 받았다고 주장하였고, 을은 과속한 사실이 없다고 주장하였다. 법원은 갑과 을 사이에 쟁점이 된 과속여부에 대하여는 판단하지 않은 채, 을이 전방주시의무를 태만히 하다가 뒤늦게 제동하는 바람에 사고가 발생한 것이므로 을에게 손해배상책임이 있다고 판단하였다. 법원의 위 판단은 적법한 것인가? (20 점)

- 변론주의의 의미 (3 점)
- 주장책임이란? (5 점)
- 과속한 사실과 전방주시의무를 태만히 한 사실은 각 주요사실인가, 간접사실인가?

1. 문제의 소재

주요사실이란 권리의 발생, 변경, 소멸이라는 법률효과를 발생시키는 법규의 직접요건사실이며 간접사실을 주요사실의 존부를 추인케 하는 사실로서 변론주의는 주요사실에만 적용되어 주요사실에 대한 당사자의 주장이 있어야 판결의 기초로 삼을 수 있다. 사안에서 과속한 사실과 전방주시의무를 태만히 한 사실이 주요사실인지 간접사실인지 문제되며 이에 따라 법원이 전방주시의무 태만을 당사자의 주장없이 고려할 수 있는지 여부가 문제된다.

2. 과실의 주요사실 여부에 대한 견해의 대립

1) 법규기준설(판)은 권리의 발생-변경-소멸이라는 법률효과를 발생시키는 법규의 직접 요건사실만이 주요사실이라고 본다. 법규기준설을 엄격히 관철시키는 입장에서는 개별 법규에서 '과실', '인과관계', '정당한 사유'와 같은 추상적이고 불확정적인 개념을 요건으로 하는 경우 위와 같은 추상적 개념 자체가 주요사실이고, 그러한 추상적 개념을 구체화하는 사실은 간접사실로 본다.

2) 준주요사실설은 과실자체는 사실에 대한 평가이고 음주운전이나 속도위반 등의 구체적 사실을 준주요사실로 보아 변론주의를 적용하자는 견해이다.

3) 주요사실설은 과실자체는 요건사실이나 주요사실은 아니고 이를 구성하는 음주운전이나 속도위반 등의 구체적 사실을 주요사실로 보아 변론주의를 적용하자는 견해이다.

4) 요건사실-주요사실 구별설은 주요사실과 요건사실은 엄격히 구별되는 개념임을 전제로 하여, '과실', '소유권', '채권'과 같은 것은 요건사실이기는 하지만 사실에 대한 법적 평가이므로 변론주의의 대상이 되는 주요사실은 아니고, 과실에 해당하는 구체적인 사실, 가령 음주운전, 과속운전, 전방주시의무 위반 등이 주요사실에 해당한다는 견해이다.

3. 결론

判例의 입장인 '법규기준설'에 따르면 과속운전의 점에 대해서 별도로 판단하지 않고 전방주시의무 위반의 점을 근거로 과실을 인정하는 것은 문제가 되지 않는다. 그러나 '준주요사실설' 또는 '요건사실-주요사실-구별설'에 따르면 과속운전 자체가 주요사실이므로, 법원이 이에 대해서는 별도로 판단을 하지 않은 채 당사자가 주장하지도 않은 전방주시의무 위반의 점을 인정하여 손해배상책임을 인정하는 것은 변론주의에 위배되어 적법하지 않다.

[제 3-2 문]

위 소송 계속 중 갑은 위 교통사고로 인하여 뇌손상에 의한 거동불능의 상태가 되었다. 이에 원고 측은 이 부분에 대하여 청구취지를 확장하였고, 신체감정결과 기대여명이 10 년일 것으로 인정되어 제 1 심 법원은 기왕치료비와 일일수익 및 위자료와는 별도로 향후 10 년간 매월 100 만 원씩 치료비를 지급하라는 판결을 선고하였고, 그 판결은 그대로 확정되었다. 그런데 그로부터 2 년이 지난 후 갑이 예상과는 달리 건강이 크게 호전된 경우 을은 어떠한 소송상의 조치를 취할 수 있는가? (10 점)

I. 서설

정기금 지급을 명하는 판결이 확정된 상태이므로, 그 후 사정변경을 이유로 정기금의 감액을

청구하기 위해서는 정기금판결에 대한 변경의 소를 제기하여야 한다.

정기금판결에 대한 변경의 소란 정기금의 지급을 명한 판결이 확정된 뒤에 그 액수산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀐 경우에 장차 지급할 정기금 액수를 바꾸어 달라는 소를 말한다(민사소송법 제 252 조).

II. 법적성질

확정판결의 변경을 목적으로 하는 소로서 소송법상의 형성의 소에 해당한다.

정기금판결 변경의 소가 전소와 소송물이 동일해야 하는지에 대해서는 견해의 대립이 있는데, 통설은 위 변경의 소는 전소와 소송물이 동일해야 한다고 보고, 이 점에서 재심의 소와 비슷한 성격이 있다고 보는 반면, 소수설은 위 변경의 소는 전소가 잘못되었음을 전제로 하는 것이 아니므로 재심의 소와 구별되고, 그 소송물은 전소에서 명한 급부내용의 변경을 구하는 것이므로 전소의 소송물과 다르다고 본다.

통설에 따르면 정기금판결 변경의 소는 종전 판결의 소송내적 효력과 기판력의 변경을 목적으로 하는 것이지, 단지 집행력의 변경을 목적으로 하는 소가 아니게 된다. 그러나 소수설에 따를 경우, 전소의 기판력과는 무관하게 전소에서 명한 급부의 내용을 장래를 향하여 변경해달라는 것이 이 소의 목적이다.

III. 요건

1. 정기금의 지급을 명한 판결일 것

여기서 정기금의 지급을 명한 판결은 정기금 방식의 배상판결만이 아니라, 정기금 방식의 연금·임금·이자지급판결 등도 포함된다.

일일수익의 배상에 대한 정기금지급판결뿐만 아니라 계속적 불법행위와 같이 장래에 걸쳐 계속적으로 발생하는 토지의 불법점거에 기한 손해배상 내지 부당이득반환을 명한 정기금판결 등도 포함된다.

2. 정기금의 지급을 명한 판결이 확정될 것

인낙조서, 화해조서, 조정조서, 확정된 화해권고결정, 조정을 갈음하는 L 결정 등도 유추적용 된다.

3. 판결확정 뒤 정기금 액수산정의 기초가 된 사정이 현저하게 바뀌었을 것

주관적 사정의 변경, 객관적 사정의 변경 모두 포함된다.

判例는 토지의 공시지가가 약 2.2 배 상승하였고 연 차임이 약 2.9 배 상승한 것에 불과하다면 형평을 크게 침해할 특별한 사정이 생겼다고 할 수 없어 현저한 사정 변경이 아니라고 판시하였다.

4. 절차

확정된 정기금판결의 당사자 또는 민사소송법 제 218 조 제 1 항에 의하여 그 확정판결의 기판력이 미치는 제 3 자이고, 제 1 심판결법원의 전속관할로 한다(민사소송법 제 252 조 제 2 항).

IV. 결론

을은 1 심법원에 정기금판결에 대한 변경의 소를 제기하여 정기금의 감액을 청구하면 된다.

< 2017 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

[문제 2]

갑은 을이 운전하는 영업용 택시를 타고 귀가하던 중 자신이 탄 택시와 그 당시 병이 운전하던 승용차가 교차로에서 충돌하는 사고를 당하는 바람에 상해를 입었다. 이에 갑은 병을 상대로 이미 지출한 치료비와 위자료 등 3 천만 원의 손해를 배상하라는 소송을 제기하였고 병은 이 소송에서 위 사고는 을의 귀책사유(구체적으로는 신호위반)로 인한 것이고 자신에게는 위 사고발생에 관한 귀책사유가 없다는 취지로 다투고 있다. 이 경우 을은 추후 예상되는 소송에서 자신의 손해배상책임을 면하기 위하여 위 소송에서 갑의 승소를 돕기 위해 보조참가를 할 수 있는가? (15 점)

1. 보조참가의 의의 및 요건

제 71 조는 소송의 결과에 이해관계가 있는 자가 보조참가를 할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 판결주문에서 판단되는 소송물인 권리관계의 존부에 의하여 직접적으로 영향을 받는 관계에 있는 제 3 자를 의미하는 것으로 보는 것이 일반적이다. 그렇다면 판결이유에서 판단되는 쟁점에 의하여 영향을 받는 관계에 있는 제 3 자는 항상 법률상 이해관계가 없는 자로서 보조참가가 허용되지 않는 것으로 보아야 하는지 문제된다. (5 점)

2. 전소 판결에서의 교통사고가 병의 귀책사유로 인한 것이 아니라 을의 귀책사유로 인한 것이 인정될 경우, 추후 갑이 을을 상대로 손해배상청구소송을 제기하거나, 을과 병 사이에 구상책임에 관한 소송이 제기될 경우 관련 판결의 증명효로 인하여 을의 손해배상책임 인정되거나 그 책임비율이 달라지게 될 가능성이 커지게 된다. 또한 참가적 효력이 전소판결의 주문에서 판단된 사항 뿐만 아니라 판결이유에서 판단된 중요한 사실관계 내지 선결적 법률관계에도 미친다고 하고 있으므로 사안의 경우 을은 갑을 위해 보조참가를 할 수 있다고 보는 것이 타당할 것이다. 判例도 위와 같은 경우 을은 법률상 이해관계를 가지는 제 3 자로서 갑을 위해 보조참가를 할 수 있는 것으로 보고 있다. (10 점)

< 2018 년도 민사소송법 연습 중간고사 >

문 1.

갑은 을과 병을 상대로 하여 을에게는 자신이 매각한 A 물건에 대한 금 2,000 만 원의 매매대금의 지급을 구하고 병에게는 금 3,000 만 원의 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 을은 갑으로부터 위 A 물건을 매수한 것이 아니라 무상으로 증여받았다고 주장하였고, 병은 갑이 자신에게 위 대여금 채무를 면제하여 주었다고 주장하였다. 이에 법원이 증거조사를 다 해 본 결과, 매매계약체결사실과 대여사실은 인정되었지만

을과 병이 제출한 증여사실과 면제사실의 진위는 밝혀지지 않은 채 변론이 종결되었다.

1. 위 경우 법원은 을과 병이 주장하는 사실여부를 어떻게 확정하여야 하는가. 또한 법원은 갑의 각 청구에 대하여 어떤 판결을 선고하여야 하고 이 경우 위 청구에 대한 판결이유에서 실시 내지 판단하여야 하는 사항은 무엇인가? (15 점)

I. 서론

부인과 항변의 개념

II. 간접부인과 항변

1. 양자의 구별기준

2. 구별의 필요성

가. 증명책임상의 차이점

나. 판결이유에서의 판단요부

III. 사안의 해결

사안에서 무상으로 증여받았다는 을의 주장은 간접부인에 해당. 따라서 을이 무상증여사실을 증명하여야 하는 것이 아니라 갑이 매매계약을 체결하였다는 사실을 증명하여야 한다(갑에게 증명책임이 있다). 따라서 법원은 매매계약체결사실을 인정하여야 한다.

한편 병의 면제주장은 항변에 해당. 따라서 갑의 대여사실은 병에 의하여 자백되어 인정되므로 병은 갑이 면제의 의사표시를 하였음을 증명하여야 한다(병에게 증명책임이 있다). 따라서 법원은 면제사실은 존재하지 않는 것으로 판단하여야 한다. 법원은 을과 병에 대한 청구를 모두 인용하는 판결을 선고하여야 한다.

이 경우 을이 주장한 무상증여사실은 부인으로서 법원의 청구인용판결에 의하여 이미 판단된 것으로 볼 수 있으므로 법원은 판결이유 중에 무상증여사실의 여부에 대한 판단을 실시할 필요가 없고 매매계약체결사실이 인정됨을 실시하면 족하다. 반면 병의 채무면제사실은 항변에 해당하므로 법원은 판결이유 중에서 대여사실이 인정됨을 실시함과 아울러 병이 주장한

채무면제사실이 인정되지 아니함을 반드시
설시하여야 한다. 만약 이를 하지 아니한 경우
판단누락의 위법을 면치 못하게 된다.

2. 병은 위 소송에서 채무면제항변이 실패할 것임이
명백할 것 같다는 생각이 들자 법원에
변론재개신청을 하였고 이에 따라 법원은 변론을
재개하였는데, 병은 여기서 갑의 주장에 대한
변제항변을 함과 아울러 이것이 받아들여지지 않을
경우에 대비하여 갑에 대한 자신의 물품대금채권
3,000 만 원으로 상계한다는 의사를 표시하였는데,
위 소송계속 중 병은 자신이 상계항변으로 주장한
위 물품대금채권의 지급을 구하는 소송을 갑을
상대로 제기하였다. 이는 적법한 것인가? (15 점)

I. 서론

중복제소금지의 원칙의 의의, 요건

당사자의 동일, 소송물의 동일, 전소의 소송계속
중에 후소가 제기되었을 것이 중복제소에 해당하기
위한 요건인데, 전후 양소의 소송물이 동일하여야
한다는 요건과 관련하여 본 사안에서는 피고 병이
상계항변으로 주장한 채권을 별소로써 청구하는
경우에 이것이 중복제소에 해당하여 금지되는
것인지의 여부가 문제된다.

II. 견해의 대립

1. 적극설 - 판례

상계항변 자체는 소송물이 아니라 방어방법에
불과, 소송계속의 효과가 생기지 않는다.

2. 소극설

상계항변에 제공된 채권의 존재에 대한 판단에는
기판력이 생긴다. 따라서 반대채권의 존재에 대한
심리가 중복되어 상호 모순, 저촉되는 판결이
선고될 가능성이 크다.

3. 절충설

원칙적으로 적극설, 다만 상계항변으로 제공된
반대채권에 관하여는 별도의 소제기를 금지하고
기왕의 소송에서 반소를 제기하도록 유도, 만일
피고가 반소를 제기하지 않고 별소를 제기한
경우에는 바로 부적법 각하할 것이 아니라 이부,

이송, 변론의 병합에 의하여 단일한 절차로
병합시켜 심리함이 타당.

III. 결론

위 각 학설 중 한 가지를 선택하여 자신의 견해를
피력하면 족함.

문 2.

을은 갑을 상대로 갑 소유의 토지에 관한
소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 이
소송에서 을은 갑의 주소를 알고 있음에도
불구하고 갑이 마치 행방불명된 자인 것처럼
허위의 주소를 기재하여 법원으로부터
공시송달명령을 받아 낸 다음, 제 3 자로 하여금
자신이 갑 소유의 토지를 매수한 것이라는 취지의
허위의 증언을 하게 함과 아울러 위조된
매매계약서 등을 증거로 제출하여 승소판결을
받았다. 그 후 이 판결은 공시송달의 방법에 의하여
확정되었고 을은 자신의 명의로 소유권이전등기를
마쳤다.

1. 그 후 위와 같은 사실을 알게 된 갑은 을을
상대로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의
말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하였다. 이
경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가?
(20 점)

I. 결론

법원은 갑의 청구를 기각하거나 소를 각하하는
판결을 하여야 한다. 또는 갑의 청구를 배척하는
판결을 하여야 한다.

II. 논거

을은 공시송달의 요건이 구비되어 있지 않음에도
불구하고 마치 그 요건이 구비된 것처럼 법원을
기망하여 공시송달명령을 받아 갑이 모르는 사이에
승소판결을 받아 을 명의로 소유권이전등기를
마쳤는데, 이와 같이 공시송달에 의한 판결편취의
경우에는 공시송달에 의한 판결정본의 송달이
유효한 것으로 보는 것이 통설, 판례의 입장이다.

따라서 을과 갑 사이의 전소에 관한 1 심법원의 판결은 적법하게 확정된 것으로 보아야 하고, 이 경우 갑은 항소의 추후보완(추완항소)의 방법이나 민사소송법 제 451 조 제 1 항 제 11 호 소정의 재심사유를 주장하여 재심신청의 방법으로 위 확정 판결의 효력을 다룰 수 있을 뿐이다.

갑은 위와 같은 방법으로 위 확정판결의 효력을 다투지 아니한 채 전소에 확정된 법률관계와 모순 또는 반대되는 권리관계를 후소에서 소송물로 주장하고 있는데 이는 전소 판결의 기판력에 저촉되는 것이다. 즉 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 확정판결에 의하여 을 명의의 이전등기가 마쳐진 경우에 갑이 다시 그것이 원인무효임을 내세워 을을 상대로 그 말소등기절차의 이행을 구하는 소를 제기하는 것은 이미 확정된 을의 이전등기청구권을 부인하는 것이어서 기판력에 저촉되는 것이다. 따라서 법원은 갑의 청구를 기각하거나(모순금지설), 소송요건의 흠결을 이유로 갑의 소를 각하(반복금지설)하여야 한다.

2. 만약 갑이 위 소유권이전등기

말소등기청구소송에서 패소 확정된 후, 다시 을을 상대로 위 토지에 관한 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구소송을 제기하였다면 이는 적법한 것인가? (10 점)

I. 결론

갑의 소는 부적법한 것이다. 따라서 법원은 부적법 각하판결을 하여야 한다.

II. 논거

대법원은 소유권이전등기 말소등기청구소송에서 패소 확정된 자가 후소로써 진정한 등기명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구를 하여 온 경우에 “후소인 진정한 등기명의회복의 이전등기청구와 전소의 말소등기청구가 모두 진정한 소유자의 등기명의회복을 위한 것으로 그 목적이 같고 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 법적 근거 내지 성질이 같아 결국 소송물이 동일하므로

후소는 전소의 기판력에 저촉되는 것’이라고 판시하고 있다.

따라서 사안에서 갑이 제기한 후소는 기판력에 저촉되는 부적법한 것으로서 각하되어야 한다.

문 3.

갑은 병 명의로 소유권이전등기가 되어 있는 A 토지 지상에 건물을 신축하여 이를 사용하고 있다. 갑은 을이 A 토지를 시효취득하였으며 자신은 이를 을로부터 매수하였다고 주장하면서 병을 피고로 하여 소유권이전등기를 구하는 대위소송을 제기하였다. 법원은 위 소유권이전등기청구사건에서 갑이 을로부터 A 토지를 매수한 사실이 인정되지 않는다는 이유로 갑의 소를 각하하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 곧 확정되었다.

위 판결 확정 후 병은 갑을 상대로 건물철거 및 대지인도청구의 소를 제기하였는데 이 소송절차에서 피고 갑은 여전히 자신은 을을 대위하여 원고 병에게 취득시효완성을 원인으로 하는 소유권이전등기절차의 이행을 구할 권리가 있다고 주장하였다. 피고 갑의 주장에 관하여 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (20 점)

I. 문제의 제기

채권자대위소송의 성질을 법정소송담당으로 파악하는 통설, 판례에 의하면 피보전채권의 존부는 당사자적격에 관한 문제이므로 당사자적격의 흠을 이유로 한 소각하 판결의 기판력이 후소와 관련하여 어느 부분에 발생하는지 문제된다.

II. 기판력의 범위 및 작용

사안에서와 같이 채권자대위소송에서의 소 각하 판결 시에 피보전채권의 존부는 주문에 기재되지 아니하나, 당해 소송요건의 부존재 부분에 관하여 기판력이 발생한다. 즉 갑의 피보전채권이 존재하지 아니한다는 전소법원의 판단에 기판력이 발생한다. 피보전채권의 부존재를 이유로 한 소각하 판결의 기판력은 전소와 동일한 소송물, 모순되는 반대관계, 선결관계 등에서 작용한다.

따라서 사안에서와 같이 갑이 소각하 판결을 선고받고 확정된 이후 전소의 상대방 당사자였던 병이 제기한 소에서 다시 위와 같은 피보전채권 즉 채권자대위권이 있음을 항변사유로서 주장하는 것은 전소판결과 모순 또는 선결관계에 해당하므로 허용될 수 없다.

Ⅲ. 결론

법원은 전소판결의 기판력에 저촉됨을 이유로 갑의 주장을 배척하여야 한다.

문 4.

갑은 을을 상대로 대여금 3,000 만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였는데 소송계속 중 '을은 갑에 대한 3,000 만 원의 지급의무의 존재를 인정하면서 그 중 2,000 만 원에 대하여는 을 소유의 스페인산 최고급 수제 기타 1 개를 대물변제하고, 그 이행이 있으면 갑은 나머지 1,000 만 원의 채무를 면제하기로 한다'는 취지의 소송상 화해가 성립되어 그 조서가 작성되었다. 갑은 위 화해 후에 을로부터 기타 1 개를 받았지만, 그 기타를 검증해 본 결과 그 기타는 화해할 당시 전제로 했던 스페인산 최고급 수제 기타가 아니라 저급의 싸구려 중국산 기타임이 밝혀졌다. 이 경우 갑은 위 화해의 효력을 다룰 수 있는가? 만약 다룰 수 있다면 어떠한 방법으로 다룰 수 있는가? (20 점)

I. 문제의 제기

소송상 화해의 성립과정에 실체법상 의사표시의 무효나 취소사유가 있는 경우에 당사자는 소송상 화해의 무효-취소를 주장할 수 있는가의 문제이다. 이는 소송상 화해의 기판력을 인정할 것인지의 여부에 따라 그 결론이 달라진다.

Ⅱ. 학설

1. 기판력 부정설

2. 무제한 기판력설

화해의 성립과정에 흠이 있더라도 그것이 민소법 제 451 조 제 1 항 소정의 재심사유에 해당하는

경우에 한하여 준재심에 의해서만 화해의 효력을 다룰 수 있는 것으로 보아야 한다는 견해.

3. 제한적 기판력설

원칙적으로 기판력을 인정하되 소송상 화해의 성립과정에 실체법상 무효나 취소사유가 있는 경우에는 기판력이 배제된다는 견해, 즉 실체법상 하자가 있는 경우에는 기판력이 배제되어 화해무효확인 소나 그 무효를 전제로 한 기일지정신청이 허용되어야 한다는 견해.

Ⅲ. 결론

기판력 부정설과 제한적 기판력설의 입장에서는 화해무효확인 소 또는 기일지정신청의 방법으로 화해의 효력을 다룰 수 있을 것이나, 무제한 기판력설의 입장에서는 그 하자가 민소법 소정의 재심사유에 해당하지 않는 이상 그 효력을 다룰 수 없게 될 것이다

< 2010 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

문 1. 甲은 乙에게 매매대금 1 억원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 그런데 甲은 乙의 주소를 알고 있음에도 불구하고 소장에 乙의 주소를 허위로 기재하였고 법원은 그 허위주소지에 소장부분 등의 소송서류를 송달하였다. 한편 甲과 공모한 丙은 위 주소지에서 자신이 乙인 것처럼 가장하여 위 소장부분을 송달받았다. 그 후 법원은 피고 乙로부터 답변서가 제출되지 않았음을 이유로 乙의 자백간주로 무변론의 원고승소판결을 선고하였고, 그 판결정본이 위와 같은 방법으로 송달되었다. 이 판결에 대한 乙의 구제방법을 모두 설명하라(50 점).

I. 문제의 제기

허위주소에 의하여 자백간주되어 판결이 편취된 경우 판결의 효력 및 그 구제방법이 문제된다.

Ⅱ. 본론

1. 학설

항소설에 의할 경우 소송절차의 안정 및 권리관계의 확정을 위하여 판결은 유효하고 재심등에 의해 구제받을 수 있다고 주장한다.

반면 무효설에 의할 경우 허위주소에 의하여 자백간주된 판결은 그 효력이 없어 항소기간이 도과되지 않으므로 항소를 통해 구제받을 수 있다고 주장한다.

2. 判例

판례는 무효설의 입장으로서 판례는 자백간주에 의한 판결편취의 경우에 허위주소에의 판결정본의 송달은 무효이고 판결정본도 아직 송달되지 아니한 상태에 있으므로, 항소기간도 진행되지 아니하여 항소를 제기할 수 있다고 본다. 따라서 허위주소송달에 의한 편취판결은 형식적으로 확정된 확정판결이 아니어서 기판력이 없다.

3. 이 사안의 경우

을은 판례 및 무효설에 의할 때 항소를 제기하여 자백을 철회하여 구제받을 수 있다.

문 2. 甲은 乙, 丙, 丁, 戊 4 인으로부터 각 금 1,000 만 원씩 4,000 만 원을 빌린 후 이들에 대한 채무를 담보하기 위하여 이들에게 자신이 소유한 1 필지의 토지에 대한 소유권이전등기의 가등기를 하여주었다. 그런데 乙, 丙, 丁, 戊는 甲이 모르는 사이에 4 인 공동명의로 가등기에 기한 소유권이전의 본등기를 하였고, 이에 甲은 乙, 丙, 丁, 戊 4 인을 공동피고로 하여 위 토지에 관한 소유권이전등기의 말소를 구하는 소를 제기하였다. 이 경우 소송절차에서 乙이 甲의 주장사실을 다투는 주장을 하고, 증거를 제출하는 경우, 丙, 丁, 戊 3 인에게는 어떤 영향이 있는가(50 점).

I. 문제의 제기

을의 주장이 다른 공동소송인이 주장한 것과 동일하게 볼 수 있는지 문제된다.

II. 본론

1. 공동소송의 형태

공유재산에 대한 소송의 경우 공유자가 처분 및 보존행위를 각자가 할 수 있으므로 합일확정이 필수적으로 요청되지 않는다.

따라서 갑의 을,병,정,무를 상대로 한 공유물에 대한 소송은 통상의 공동소송에 해당한다.

2. 공동소송인간의 주장공통의 원칙

(1) 의의

주장공통의 원칙이란 어느 당사자이든 변론에서 주장하였으면 되고 반드시 주장책임을 지는 당사자가 진술하여야 하는 것은 아니라는 원칙으로 대립당사자 사이에는 당연 인정되지만 통상 공동소송인 사이에서도 공동소송인중 1 인이 상대방의 주장사실을 다투며 항변하는 등 다른 공동소송인에게 유리한 주장을 할 때 다른 공동소송인의 원용 없이도 그에 대하여 효력이 미치는지 문제된다.

(2)학설 및 판례

한정적 긍정설은 공동소송인간 서로 모순된 사실인정으로 나아가는 것을 막아 사법불신을 방지하고 항변에 의한 이익에 대하여 원용을 하지 않는 것은 그 이익을 받고 싶지 않다기 보다는 공동소송인 독립의 원칙의 물이해, 본인소송에 있어서의 불완전성에 기인한다고 보아 다른 소송인 중 한 사람에게 의하여 공통사실이 주장되었을 때 다른 공동소송인이 이와 저촉되는 행위를 적극적으로 한 바 없고 다른 공동소송인에게 이익이 되는 한 그 자에게도 효력이 미친다고 보는 견해가 있으나

판례는 민사소송법 제 66 조의 명문의 규정과 민사소송법이 취하고 있는 변론주의 소송구조등을 비추어 주장공통의 원칙을 부정한다.

(3) 검토

생각건대, 주장공통의 원칙은 대립당사자 사이에서만 적용하는 것이고 만일 이를 인정하면 변론주의의 주장책임을 부정하는 결과가 되며 법원의 석명권이나 소송지휘권을 적절히 행사하여 이를 해결할 수 있기에 판례의 입장이 타당하다.

III. 결론

판례의 입장에 의할 때 을의 주장은 병, 정, 무에게 효력이 미치지 않는다.

문 3. 甲은 乙이 甲의 토지를 불법으로 점유하고 있다고 주장하면서 乙에 대한 토지인도청구소송을 제기하였다. 법원은 乙의 임차권에 기한 항변을 배척하고서 甲의 청구를 인용하는 판결을 선고하였다. 乙은 이 판결에 대해 항소한 후 항소심에서 위 임차권의 존재에 대한 확인청구의 반소를 제기하였는데, 甲이 乙의 반소에 대해 동의하지 않고 이의한 경우, 乙의 반소는 적법한 것인가. 그 근거를 제시하여 답하라(25 점).

I. 문제의 제기

을의 항소심에서의 반소가 적법한지 문제된다

II. 본론

1. 반소의 요건

① 본소와 동종의 소송절차, ② 본소와 공통관할, ③ 본소가 사실심 변론종결 전일 것, ④ 본소와 반소의 상호관련성, ⑤ 본소절차를 현저히 지연시킬 목적이 아닐 것을 요한다.

2. 항소심에서의 반소

민사소송법 제 412 조 제 1 항에 따라 항소심에서의 반소가 허용되기 위해서는 심급의 이익을 해할 우려가 없거나 상대방의 동의가 존재하는 경우에 가능하다.

이때 심급의 이익을 해할 우려가 없는 경우라 함은 중간확인인 반소, 제 1 심에서 충분히 심리한 쟁점과 관련된 반소, 항소심에서 추가된 예비적 반소등을 의미한다.

3. 이 사안의 경우

사안에서 을의 임차권의 존재에 대한 확인청구의 반소는 중간확인인 소 및 1 심에서 충분히 심리한 쟁점과 관련된 반소이므로 갑의 심급의 이익을 해할 우려가 없다.

따라서 갑의 동의 없이도 반소를 제기할 수 있다.

III. 결론

을의 반소는 적법하다.

문 4. 甲은 乙에 대하여 1,000 만 원의 대여금반환청구소송을 제기하였다. 이 소송에서, (1) 乙은 변제의 항변 및 상계의 항변을 제출하였는데 법원의 심리 및 판단의 순서는 어떻게 되는가?
(2) 乙은 1,500 만 원의 매매대금채권을 가지고 상계한다는 항변을 제출하였으나 여기서 乙의 채권이 부존재하는 것으로 판단되어 甲의 청구가 인용되고 그 판결이 확정되었다. 그 후 乙이 위 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기하는 것은 허용되는가?

(1)문의 해결

피고가 변제항변과 상계항변을 함께 제출하였을 때 먼저 변제항변을 심리하여야 한다.

(항소심에서 상계항변을 받아들여 원고의 청구를 기각하는 것은 불이익변경금지원칙의 예외라는 것은 함정) 나아가 乙의 반소는 방어방법 이상의 적극적 내용이 없으니 부적법하나, 이러한 반소장 제출은 채무 전액이 변제로 소멸하였다는 피고의 주장에 따른 부대항소장 제출로 선택할 수 있음을 실시하여 원고 청구 전액을 기각하더라도 불이익변경금지 원칙에 반하지 않는다.

(2)문의 해결

상계항변이 배척된 경우 - 1,000 후소: 기각 /

500 후소: 기판력 X

상계항변이 인용된 경우 - 1,000 후소: 각하 /

500 후소: 기판력 X

단, 종전 소송에서의 판단 이유를 합리적인 이유 없이 배척할 수 없게 되는 한 증명효를 받게 된다.

문제 4-(1)

I. 결론

법원은 변제의 항변을 심리 및 판단을 하고 난 뒤에 이유가 없을 때에 한하여 상계의 항변을 심리 및 판단할 수 있다.

Ⅱ. 논거

상계의 항변은 예비적, 출혈적 항변에 해당하는 경우로서 법원은 최후에 판단해야한다.

따라서 상계의 항변 이전에 변제의 항변이 존재하는 경우에는 법원은 변제의 항변을 먼저 심리한 후 이것이 이유가 없을 경우에 한하여 상계의 항변을 검토해야 당사자를 보호할 수 있다.

문제 4-(2)

I. 문제의 제기

상계항변은 민사소송법제 216-2 항에 따라 판결이유에서 판단되나 예외적으로 기판력이 발생하는 바 자동채권의 부존재에 대한 판단에도 발생하는지 문제된다.

Ⅱ. 본론

1. 상계항변에 대한 기판력의 발생범위

민사소송법 제 216 조 2 항에 따라 상계항변의 경우에 기판력이 발생하고 그 발생범위는 발생, 배척, 채택 모두에 대하여 발생한다.

발생의 경우 자동채권의 존부에 대해서는 상계로써 대항한 액수의 한도에서 기판력이 생긴다.

배척의 경우 자동채권의 부존재에 대하여 기판력이 발생한다.

상계항변을 채택하여 원고청구를 기각하는 경우 기판력의 발생범위에 대하여 견해가 대립하나 수동채권과 자동채권이 다함께 존재하였다가 그것이 상계에 의하여 소멸된 점에서 기판력이 생긴다.

2. 이 사안의 경우

을은 1500 만원의 자동채권으로 소구채권에 대해 상계하려 하였으나 배척당하였으므로 1500 만원의 자동채권의 부존재에 대하여 기판력이 발생하였다.

따라서 후소로서 다시 매매대금의 이행청구를 하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

Ⅲ. 결론

허용되지 않는다.

문제 4-(3)

1. 결론

모두 허용되지 않는다.

2. 논거

1) 민소법 제 216 조 제 2 항

피고가 상계항변을 제출하였을 경우에 자동채권의 존부에 대하여 비록 판결의 이유중에서 판단하지만 상계로써 대항한 액수의 한도 내에서는 기판력이 발생한다.

2) 학설

상계항변이 채택되어 인정된 경우 어느 범위에 관하여 기판력이 인정되는가에 관해 현재 반대채권이 소멸되어 존재하지 않는다는 점에 기판력이 생긴다는 견해

소구채권과 반대채권이 함께 존재하였다가 그것이 상계에 의하여 소멸된다는 점에 기판력이 생긴다는 견해가 대립한다.

3) 부당이득반환청구의 적법성

어느 견해에 의하든 부당이득을 원인으로 한 채소가 금지된다는 점에서 동일하다.

사안 1 에서와 같이 원고인 갑이 반대채권이 당초부터 존재하지 않는다고 주장하면서 부당이득반환청구를 하는 것이나

사안 2 와 같이 피고인 을이 소구채권이 당초부터 존재하지 않는다고 주장하면서 부당이득반환청구를 하는 것은 기판력에 저촉되어 허용되지 않는다.

< 2012 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

1. 甲이 乙을 상대로 매매대금의 지급을 구하는 소를 제기한 후 그 증거로 매매계약서를 제출하자, 乙은 위 매매계약서상의 인영이 자신의 인장에 의한 것임은 인정하지만, 丙이 자신의 승낙을 받지 아니한 채 무단으로 날인한 것이라고 주장하였고, 이에 대하여 甲은 丙이 날인한 것은 맞지만 丙이 乙의 승낙을 받아서 날인한 것이라고 주장하였다. 법원이 심리한 결과 丙이 위 매매계약서에 날인을

할 때 乙의 승낙을 받았다는 것을 인정할 아무런 증거가 없었다. 이 경우 법원은 위 매매계약서를 증거로 사용할 수 있는가? (20 점)

답 : 증거로 사용할 수 없다. 즉 증거가치가 없다 (5 점).

이유 : 매매계약서는 처분문서이므로 형식적 증거력이 인정되면 특별한 사정이 없는 이상 실질적 증거력도 인정되는데, 실질적 증거력을 인정받기 위해서는 그 전제로서 형식적 증거력이 인정되어야 한다(5 점).

문제는 본건 매매계약서에 관하여 형식적 증거력을 인정할 수 있는가이다. 문서의 형식적 증거력(진정성립)에 관한 증명책임은 거증자(문서제출자)에게 있다. 문서의 진정성립의 추정에 관한 민소법 358 조는 문서상에 그 작성명의인의 의사에 기한 서명이나 날인이 있는 경우에 그 진정성립이 추정된다는 것이므로, 본 사안과 같이 날인행위가 작성명의인(을) 이외의 제 3 자(丙)에 의하여 행해진 것이 밝혀진 경우에는 위 추정규정은 적용되지 않는다(5 점). 따라서 문서제출자인 甲은 그 날인행위가 작성명의인인 乙로부터 위임받은 정당한 권원(즉 乙의 승락)에 기하여 행해진 것이라는 사실을 증명할 책임이 있는데 이를 인정할 증거가 없으므로 매매계약서는 형식적 증거력이 인정되지 않고, 따라서 실질적 증거력도 인정되지 않는다(5 점).

2. 甲은 乙을 상대로 1 억 원의 보증채무의 이행을 구하는 소를 제기하였고, 소송계속 중 주채무자 丙이 乙측에 보조참가를 하였다. 이 소송에서 丙은 자신의 주채무가 존재하지 않는다고 주장하였지만, 乙은 주채무와 보증채무의 존재를 모두 인정하였는데, 법원은 乙의 진술을 받아들여 甲의 청구를 모두 인용하는 판결을 선고하였고, 이 판결은 그대로 확정되었다.

1) 乙은 위 판결에 따라 1 억원을 甲에게 지급한 후, 丙을 상대로 구상금의 지급을 구하는 소를 제기하였는데, 이 소송에서 丙은 주채무가 존재하지 않는다고 다룰 수 있는가? (10 점)

답 : 다룰 수 있다(3 점).

이유 : 참가적 효력에 관한 통설, 判例는 피참가인이 패소하고 난 후 피참가인이 참가인을 상대로 한 소송(2 차소송)을 제기한 경우, 참가인이 자신이 참가한 소송에서의 확정된 판결의 내용이 피참가인에 대한 관계에서 부당하다고 다룰 수 없는 구속력으로 본다. 그러나 민소법은 제 77 조에서 일정한 경우 이러한 참가적 효력이 배제되는 경우를 규정하고 있는데, 본 사안은 제 77 조 제 1 호 후단의 사유에 해당하기 때문이다. 즉 본 사안은 제 76 조 제 2 항에 따라 참가인의 행위와 피참가인의 행위와 어긋나게 되어 효력을 가지지 아니하게 된 경우에 해당되므로(보조참가인 丙은 주채무의 존재사실을 다투었는데 피참가인 乙은 이를 인정하며 자백하였다) 제 77 조 규정에 의하여 참가적 효력은 배제된다(7 점).

2) 乙이 위 판결이 확정되었음에도 甲에게 1 억원을 지급하지 않아, 甲이 丙을 상대로 주채무의 지급을 구하는 소를 제기한 경우, 이 소송에서 丙은 주채무가 존재하지 않는다고 다룰 수 있는가? (10 점)

답 : 다룰 수 있다(3 점).

이유 : 통설, 判例에 의하면 참가적 효력은 위와 같은 것인데, 이는 피참가인과 참가인 간에 생기는 구속력일 뿐 피참가인의 상대방과 참가인 간에 생기는 것이 아니기 때문이다; 참가적 효력의 주관적 범위(7 점).

(다만, 참가적 효력에 관한 신기판력설의 입장에서는 이를 다룰 수 없다고 볼 것이다)

3. 원래 甲의 소유이던 A 토지에 관하여 乙이 관련문서를 위조한 다음 이를 사용하여 자신의 명의로 소유권이전등기를 마쳤다. 丙은 甲으로부터 위 토지를 매수하고 난 후 甲을 대위하여 乙을 상대로 소유권이전등기의 말소등기청구의 소를 제기하였으나 패소판결이 선고되었고 그 판결이 그대로 확정되었다.

1) 위와 같이 丙이 소송을 제기하였다가 패소한 사실을 모르고 있던 甲이 다시 乙을 상대로 소유권이전등기말소청구의 소를 제기한 경우, 甲이 제기한 소는 적법한 것인가? (20 점)

답 : 判例, 통설에 의하면 적법하다(5 점).
 이유 : 채권자대위소송의 판결의 기판력이 채무자에게 미치는가의 문제이다.
 적극설, 소극설, 절충설(채무자가 소송고지 등 어떤 사유로든지 간에 소송계속중인 사실을 알았을 때에는 미치지만 그렇지 않은 경우에는 미치지 않는다)이 있으나 절충설이 통설, 判例의 입장이다.
 사안의 경우 甲은 丙이 대위소송을 제기하여 패소하였다는 사실을 모르고서 다시 소를 제기한 것이므로 적법하다(15 점).

2) 위 1)항의 소송이 계속되던 중, 乙은 소송 외에서 甲의 주장을 인정하고 甲으로부터 A 토지를 다시 매수하였는데, 甲이 제기한 소송은 乙의 불출석으로 인하여 甲이 무변론 승소판결을 받았고 그대로 확정되었다. 그 후 乙이 사망하고 乙의 상속인인 丁이 A 토지에 관한 상속을 원인으로 한 소유권이전등기를 마치자 甲은 위 확정판결에 기하여 丁 명의의 소유권이전등기를 말소하였다. 이에 丁은 甲을 상대로 피상속인인 乙의 위 매매를 원인으로 한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 丁이 제기한 위 소는 적법한 것인가? (40 점)

1. 문제의 소재
2. 변종된 승계인
 정은 민소법 제 218 조 제 1 항의 무변론 판결 선고 뒤의 승계인에 대하여 갑과 을 사이의 전소 확정판결은 을의 상속인 정에게도 미친다. 따라서 갑은 승계집행문을 부여받아 정 명의의 소유권 이전등기를 말소 할 수 있다.
3. 기판력의 적용 범위
 - 1)기판력의 발생
 확정판결의 기판력은 소송물로써 주장된 법률관계의 존부에 관한 판단에 관하여만 발생하는

것이고 전소와 후소가 소송물이 동일한 경우에 작용한다.
 2)소결
 사안의 경우 전소의 소송물은 갑의 을에 대한 A 토지에 관한 소유권이전등기말소청구권의 존부인 반면, 후소의 소송물은 정이 갑에 대한 소유권이전등기청구권의 존부이므로 소송물이 다르다. 따라서 전소에서 A 토지에 관한 소유권이전등기가 원인무효임을 이유로 등기의 말소를 명하는 판결이 확정되었더라도 그 확정판결의 기판력은 그 소송물에만 미치고 전소에서 문제된 것과 전혀 다른 청구원인인 매매에 기하여 상대방에 대하여 소유권이전등기를 청구 할 수 있다.
 3) 모순관계 검토

전소와 후소의 소송물이 동일하지는 않지만 서로 모순관계에 있으므로 후소는 전소의 기판력에 저촉되는 것이 아닌가 하는 문제와, 정이 후소에서 청구원인 사실로서 주장하는 매매사실은 전소의 무변론 판결 전에 존재하였던 공격방어방법에 해당하여 기판력의 시적범위에 따른 실권효가 미치는 것이 아닌가하는 문제가 있다.
 생각건대, 기판력의 시적 범위에 따른 실권효는 전소와 후소가 동일한 소송물일 때 논의 가능하기에 실권효는 문제되지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 결론
 소유권이전등기말소판결이 확정된 뒤에 거기서 패소한 상대방이 동일한 토지에 관하여 위 판결 전의 매매를 원인으로 소유권이전등기를 청구한 것은 전소판결의 기판력에 저촉되지 않는 것으로 적법한 것이다.

< 2013, 2016 년도 민사소송법 연습 기말고사 >

[제 1 문]
 甲은 주택건설사업 등을 영위하는 건설회사이고, 乙은 연립주택을 철거하고 새로이 아파트를 건축하려고 조직된 재건축조합이다. 甲과 乙은

공동사업주체로서 기존의 연립주택을 철거하고 그 지상에 아파트를 건설하기로 하며, 乙의 조합원들에 의한 사업부지 제공의 대가로 아파트의 일부 세대를 乙의 조합원들에게 분양하고 乙의 조합원들이 일정한 분담금을 납부하는 한편, 나머지 일반분양세대를 분양하여 그 대금을 甲과 乙에게 귀속시키기로 하는 내용의 이 사건 시행·시공계약을 체결하였다. 이 사건 계약에 의하면 甲과 乙은 이 사건 아파트를 공동으로 분양하고 수익과 손실을 공동으로 부담하는 것으로 되어 있었다. 이에 따라 甲과 乙이 공동으로 매도인이 되어 2014. 10. 20. 丙에게 일반분양세대인 이 사건 아파트를 분양하는 내용의 분양계약을 작성하여 이 사건 분양계약을 체결하였다.

1. 이 사건 아파트 완성 후 丙은 이 사건 분양계약에 정해진 분양대금을 지급하지 않고 있다. 이에 따라 甲과 乙은 丙을 상대로 분양대금의 지급을 청구하는 소를 제기하였다. 이 소송 도중에 乙은 丙과 소송 외에서 원만히 합의한 후 이에 따라 소를 취하하였다. 이러한 소의 취하는 유효한가? (20 점)

I. 문제의 소재

갑, 을과 병 사이의 소송이 통상공동소송인지 필수적공동소송인지에 따라 심판의 방식이 달라지므로, 먼저 소송형태를 확인한 후 을과 병 사이의 소취하 효력을 검토해야 한다.

II.. 공동소송의 형태

갑과 을은 공동사업주체로서 재건축사업을 진행하기 위해 상호출자한 조합계약에 해당한다. 따라서 갑과 을이 병과 체결한 분양계약으로 얻은 분양대금지급청구권은 조합재산에 해당하여 준합유 관계에 있다고 보아야 한다. 조합재산을 처분하는 경우 모든 조합원의 동의가 필요한바, 공동소송의 형태도 조합원 전원이 당사자가 되어야 하는 고유필수적공동소송에 해당한다.

III. 고유필수적공동소송의 심판방법

고유필수적 공동소송의 경우 민사소송법 제 67 조에 따른 연합성의 원칙이 적용된다. 따라서 공동소송인 중 1 인의 행위가 유리한 행위인 경우 전원에 효력을 미치지만, 불리한 행위인 경우 전원의 의사합치로 행위하여야 한다.

사안에서 을이 행한 소취하는 불리한 소송행위 해당하므로 갑과 함께 행위해야 함에도 단독으로 행위하였기에 소취하는 효력이 없다.

IV. 결론

을의 소취하는 1 인이 한 것이므로 효력이 없다.

2. 그런데 丙이 이 사건 소송에 앞서 甲과 乙을 상대로 이 사건 아파트에 관하여 소유권이전등기청구의 소(이하 '전소라 한다)를 제기하였는데, 법원은 甲과 乙은 丙으로부터 2 억 원을 지급받음과 동시에 甲에게 소유권이전등기절차를 이행하라는 판결을 하였고 이 판결은 확정되었다. 이 사건 소송에서 전소판결의 주문에서 인정한 2 억 원의 반대급부를 이행하라는 판단에는 기판력이 발생하는가? (20 점)

I. 문제의 소재

상환이행판결에 있어서 주문에 나타난 반대채권에 대하여도 기판력이 발생하는지 문제된다.

II. 기판력의 객관적 범위

기판력의 객관적 범위는 원칙적으로 확정판결의 소송물, 즉 주문에 나타난 것에 한하여 미친다(민사소송법 제 216 조). 따라서 판결이유 중 판단인 선결적 법률관계나 항변에 대해서는 기판력이 발생하지 않음이 원칙이다.

상대방의 동시이행항변이 인정되어 내려진 상환이행판결의 경우, 주문에 반대채권이 나타나는데, 이는 항변에 관한 판단일 뿐 소송물에 관한 판단이 아니므로, 주문에 나타난 반대채권의 존부나 수액에 대하여는 기판력이 발생하지 않고 동시이행항변권이 존재한다는 사실에만 기판력이 미친다는 것이 판례의 입장이다.

Ⅲ. 결론

따라서 2억 원의 반대급부를 이행하라는 내용에는
기판력이 발생하지 않는다.

**3. 이 사건 소송 계속 중 甲, 乙은 丁에게 자신이
丙에 대하여 가지는 분양대금채권을 양도하였다.
이 경우 丁 자신이 이 사건 소송에 참가할 수 있는
방법에는 무엇이 있는가? (10 점)**

I. 문제의 소재

소송의 목적인 권리를 양수한 정이 계속 중인
소송에 참가할 수 있는 방법이 문제된다.

Ⅱ. 참가승계 (민사소송법 제 81 조)

참가승계를 하기 위해서는 타인간의 소송이 계속
중일 것, 소송의 목적인 권리, 의무의 승계가 있을
것이 요구된다. 사안의 경우, 정은 소송의 목적인
권리 자체를 승계하였으므로, 사실심변론종결
전까지 독립당사자참가의 방법으로 참가승계를 할
수 있다.

이 때 갑, 을과 정 사이에 양도에 대한 다툼이 없는
경우, 독립당사자 참가 중 편면참가의 방법으로
병에게만 참가할 수 있고, 다툼이 있는 경우에는
쌍면참가의 방법으로 갑, 을과 병에게 각각 참가할
수 있다.

Ⅲ. 독립당사자참가 (민사소송법 제 79 조)

타인 간 소송이 계속 중 제 3자가 원, 피고 양쪽
또는 한쪽을 상대방으로 하여 소송목적의 전부나
일부가 자기의 권리라고 주장하거나, 소송결과에
따라 권리가 침해된다고 주장하면서 당사자로서 그
소송절차에 참가하는 것을 독립당사자참가라고
한다.

판례에 따르면, 채권양도는 준물권행위로서 유효한
양도시 채권자와 양수인은 양립할 수 없는 관계에
있으므로 양수인의 소송 참가는 적법하다.

갑, 을이 분양대금채권을 청구하는 것과 정이 해당
채권을 자신의 권리라고 주장하며 참가하는 것은

양립불가능하므로 정은 독립당사자참가도
가능하다.

Ⅳ. 보조참가 (민사소송법 제 71 조)

보조참가의 요건으로는 타인 사이에 소송이
계속중일 것, 참가인이 피참가인의 소송결과에
대하여 법률상 이해관계가 있을 것, 참가신청이
있을 것, 소송절차를 현저히 지연시키지 아니할 것
등이 있다.

정은 갑, 을이 패소하면 자신이 양받은 권리를
행사하지 못하는 지위에 있으므로, 판결결과와
법률상 이해관계 있는 자에 해당하고, 정의 참가로
소송이 현저히 지연될 만한 사정은 보이지
않으므로 보조참가를 할 수 있다. 보조참가는
보충성을 요하는 것도 아니므로 독립당사자참가가
가능하더라도 보조참가의 방식으로 소송참가가
가능하다. 보조참가는 소제기의 성질을 갖지 않기
때문에 상고심인 3심에서도 가능한데, 사안의 경우
항소심 계속중이므로 당연히 참가가 가능하다.

V. 결론

정은 참가승계, 독립당사자참가, 보조참가의
방법으로 소송에 참가할 수 있다.

[제 2 문]

갑 소유 2층 건물을 갑의 아들 A로부터 임차하여
사용하고 있는 을은 위 건물 중 1층 부분을 병에게
전대하여 을과 병이 위 건물을 나누어 점유,
사용하고 있다.

이에 대하여 갑은 을과 병이 권원 없이 위 건물을
점유하고 있다고 주장하면서 을과 병을 상대로
소유권에 기한 각 점유부분의 인도 및 그 부분의
사용, 수익으로 인한 차임 상당의
부당이득반환청구의 소를 제기하였다. 갑은 위 소와
관련하여 점유이전금지가처분 등 보전처분을 하지
않았다.

1. 만약 병이 정에게 1층 부분을 다시 전대하여
현재 정이 1층 부분을 점유하고 있다는 사실을
갑이 사실심 변론종결 이전에 알았다면, 갑은 정에

대하여 어떠한 소송법적 조치를 할 수 있는가?

(15 점)

I. 문제의 소재

당사자 간의 동일성이 인정되는 경우

당사자표시정정절차를 이용할 수 있으나, 사안에서 정과 병은 동일성이 인정 될 수 없기 때문에 이는 허용될 수 없다. 당사자 간 실체법상 권리, 의무의 승계가 있는 경우에는 소송승계제도를 이용할 수 있으므로, 정이 병으로부터 점유를 전대받아 점유 중인 자로서 병의 승계인에 해당하는지 문제된다.

II. 소송승계의 의의

소송승계라 함은 소송계속 중에 소송의 목적인 권리관계가 변동함으로써 새로운 승계인이 종전의 당사자에 갈음하여 당사자가 되고 그에 따라 당사자적격이 승계되며 당해 소송을 인계받게 되는 것이다.

III. 승계인의 범위 (민사소송법 제 82 조 제 1 항)

소송물인 권리관계 자체를 승계한 자 뿐만 아니라 그 계쟁물을 승계 받은 자도 승계인에 포함된다. 사안의 경우 정은 물권적 청구권을 소송물로 하는 소송의 사실심 변론종결 이전에 피고로부터 계쟁물의 일부를 넘겨받았으므로 피고 적격의 승계인에 해당한다. 따라서 소송계속 중 제 3 자가 소송목적인 의무의 목적물을 승계한 경우에 해당되어 갑은 정으로 하여금 소송을 인수하게 할 수 있다

IV. 결론

갑은 정을 상대로 병의 지위를 이어받도록 하는 인수승계신청을 할 수 있다.

2. 위 소송에서 제 1 심법원은 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였고, 그 판결이 확정되었다. 그 이후에 병이 1 층 부분을 정에게 전대하여 정이 그 부분을 점유하고 있다는 사실이 집행단계에서 밝혀지자 갑은 정을 상대로 전소확정 판결과 동일한 내용의 소를 별도로 제기하였다.

법원은 이에 대하여 어떻게 판결하여야 하는가?

(15 점)

I. 문제의 소재

병에 대한 확정판결의 효력이 정에게 확장되는 것인지 문제된다. 이는 갑과 병 간의 소송의 소송물이 물권적 청구권에 기한 것인지의 여부, 정의 점유시점이 변론종결 후인지의 여부에 따라서 결정된다.

II. 기판력의 주관적 범위

1. 총설

확정판결의 기판력은 당사자는 물론 변론종결 뒤의 승계인에 대해서도 그 효력이 미친다(민법 제 218 조 제 2 항).

변론종결 뒤의 특정승계는 피승계인으로부터 소송물 자체를 승계한 경우에 국한하지 아니하고, 계쟁물을 승계한 경우에도 포함하는데, 이러한 입장을 적격승계설이라 한다.

2. 승계인의 범위

전소 변론종결 뒤 승계인인지 여부에 관해서는 원칙적으로 소송물이론의 입장에 따라 달리 보고 있다.

判例는 구소송물 이론을 따라 원고의 청구권이 물권적 청구권인 경우에는 대세적 효력이 있으므로 피고로부터 계쟁물을 승계한 자는 승계인의 범위에 포함되지만, 채권적 청구권인 경우에는 대인적 효력밖에 없으므로 승계인에 포함되지 않는다 판시한다. 반면, 신이론의 입장에서는 그 청구권이 물권적이냐 채권적이냐를 불문하고 일률적으로 제 218 조 제 1 항의 승계인에 해당하는 것으로 본다.

3. 사안의 경우

갑과 병 간의 소송의 소송물은 물권적 청구권에 기한 것으로서 정은 변론종결 이후부터 위 건물 일부를 점유하게 되었다. 따라서 정은 변론종결 후에 계쟁물을 양수한 승계인에 해당하여 그에 대해 기판력이 미치게 된다. 따라서 갑은 승계집행문을 부여 받아 정에 대하여 강제집행을 할 수 있다.

Ⅲ. 결론

그럼에도 갑이 동일한 소송물에 대하여 소를 제기한 것은 소의 이익이 없으므로 법원은 그 소를 각하하는 판결을 선고하여야 한다.

3. 위 소송에서 제 1 심 법원은 갑의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였는데, 이에 대하여 을만이 항소하였다. 항소법원이 심리한 결과 갑의 청구가 부당하다고 판단되면 항소심 법원은 병에 대하여서도 제 1 심 법원의 판단과 달리 유리한 판결을 선고할 수 있는가? (10 점)

I. 문제의 소재

갑이 을과 병을 상대로 하는 소송은 민사소송법 제 65 조 후문의 통상공동소송에 해당하는지, 나아가 공동소송인 독립의 원칙이 적용되는지 여부가 문제된다.

Ⅱ. 통상공동소송

통상공동소송이란 공동소송인 사이에 합일확정이 필수적이 아닌 공동소송을 말한다. 사안에서 갑이 을과 병을 상대로 하는 소송은 민사소송법 제 65 조 후문 통상공동소송에 해당한다.

Ⅲ. 공동소송인 독립의 원칙

1. 의의

공동소송인 독립의 원칙이란 통상공동소송에 있어서 각 공동소송인은 다른 공동소송인에 의한 제한, 간섭을 받지 않고 각자가 독립하여 소송수행을 할 수 있는 것을 말한다.

2. 내용

소송요건의 존부를 각 공동소송인마다 개별적으로 심사하여야 하며(소송요건의 개별적 조사), 공동소송인 중 1 인의 소송행위는 유·불리를 막론하고 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다. 또한 각 공동소송인은 공격방어방법을 개별적으로 제출할 수도 있다(소송자료의 독립). 공동소송인 1 인에 대한 사항은 다른 공동소송인에게 영향이 없고, 공동소송인 한 사람에 대해 변론 분리를 할 수 있다(소송진행의 독립).

공동소송인 간에 재판통일이 필요 없으며, 판결내용이 상이하게 되어도 무방하다. 법원은 전부판결을 해야하나, 공동소송인의 한 사람에 대해 판결하기에 성숙한 때에는 일부판결을 할 수 있다(재판의 독립).

상소에 관하여 전부판결에 일부상소한 경우에는 독립성의 원칙 때문에 상소불가분 원칙이 적용되지 않아 일부이심되며, 불이익변경금지 원칙이 적용되어 상소한 청구만 일부심판의 대상이 되고 항소하지 않은 자에 대한 판결은 분리되어 확정된다.

Ⅳ. 결론

피고 을만 항소하였으므로 그 항소의 효력은 병에게 미치지 않고 병에 대한 판결은 분리되어 그대로 확정되므로 항소심의 심판대상이 아니다. 따라서 항소심 법원은 병에 대하여는 유리한 판결을 선고할 수 없다.

[제 3 문] = 2013 년도 민사소송법 연습

甲은 1994. 1. 15. A로부터 그 소유의 X 토지를 매수하였다. 그런데 甲은 X 토지에 연접한 을 소유의 Y 토지가 X 토지에 포함되었다고 착각하고 1994. 1. 15.부터 X, Y 토지를 모두 텃밭으로 계속하여 점유-사용해오고 있다. 乙은 2015. 1. 3. Y 토지를 丙에게 매도하였고, 매매대금은 2 천만 원으로 정하였다. 이후 丙은 2015. 1. 10. Y 토지에 대하여 소유권이전등기를 경료하였다.

1. 丙은 2016. 1. 29. 甲을 상대로 하여 Y 토지를 인도하라는 내용의 소를 제기하였다. 甲은 자신이 1995. 1. 15. 부터 20 년 이상 점유하여 취득시효로 Y 토지의 소유권을 취득하였다고 주장하였다. 이에 대하여 丙은 처음에는 甲이 1995. 1. 15.부터 Y 토지를 점유한 점을 인정하였다가 이후 이를 번복하여 甲이 1994. 1. 15.부터 점유하였으므로 자신은 시효취득자에게 대항할 수 있는 제 3 자라고 주장한다. 증인 정은 甲이 1994. 1. 15.부터 점유하였다고 증언하였고, 법원은 정의 증언이 신빙성이 있다고 판단하였다. 丙의 청구에 대하여 법원은 어떻게 판단할 것인가? (30 점)

I. 점유취득시효 완성자의 법적 지위 (10 점)
20 년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유한 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득하게 된다(민법 제 245 조 제 1 항).

그러나 부동산에 대한 점유취득시효 완성을 원인으로 하는 소유권이전등기청구권은 채권적 청구권이므로 취득시효가 완성된 후 점유자가 그 등기를 하기 전에 제 3 자가 소유권이전등기를 경료한 경우, 점유자는 그 제 3 자에 대하여는 시효취득을 주장할 수 없는 것이 원칙이다.

II. 취득시효의 점유개시일에 변론주의가 적용되는지 여부 (15 점)
애초 甲의 점유개시일이 1995. 1. 15.이라는 점에 甲과 丙 사이에 진술이 일치하였지만, 취득시효의 점유개시일은 간접사실이므로 자백이 성립하지 않는다.

법원은 증거에 의하여 점유개시일을 정할 수 있으므로, 甲의 취득시효 기산점을 1994. 1. 15.라고 판단하여 丙을 취득시효완성 이후 소유권이전등기를 경료한 자라고 판단한다.

III. 결론 (5 점)
甲의 취득시효가 2014. 1. 15. 완성되었으나 甲이 등기를 하기 전에 丙이 소유권이전등기를 경료하였으므로, 甲은 丙에 대하여는 시효취득을 주장할 수 없음. 丙의 청구는 인용됨.

2. 위 사안과 달리, 乙은 자신이 丙에게 Y 토지를 매도한 것이 아니라 자기와 일면식이 없는 소외 무가 등기서류를 위조하여 자신의 대리인 행세를 하여 丙에게 매도하고 위 토지의 등기를 경료한 것이라고 하면서 丙을 상대로 위 토지에 관한 소유권이전등기 말소등기청구의 소를 제기하였다고 가정한다. 이 소송에서 이 사건 등기가 원인무효라는 사실은 누가 증명하여야 하는가? (10 점)

I. 등기의 추정력

1. 원칙
증명책임의 일반원칙에 따르면 매매계약을 체결한 자가 매도인으로부터 소유권취득원인사실을 증명해야 한다.

2. 등기명의자의 증명책임 면제 및 완화
부동산 등기부상 소유자로 등기되어 있는 자는 특별한 사정이 없는 한 그 부동산의 소유자로 추정된다.

II. 判例
判例는 부동산에 관한 소유권 이전등기는 권리의 추정력이 있어 특별한 사정이 없는 이상 부동산의 소유자로 법률상 추정되며, 등기된 권리의 존재 귀속, 등기원인의 존재 유효, 등기절차의 적법성도 함께 추정되어 그 등기가 위법하게 된 것이라고 주장하는 상대방에게 그 추정력을 번복시킬 반대사실을 입증할 책임이 있으며, 그 책임의 정도는 법관의 의심을 가지게 하는 것에 그치는 것이 아니라 법관에게 확신을 주는 본증의 방법으로 해야 한다고 본다. 또한 그 계약 및 등기가 대리인에 의해 행해졌더라도 등기가 되어 있는 이상 그 대리인이 적법한 대리권을 수여받아 유효한 대리행위를 한 점도 추정된다.

III. 학설
등기의 추정력에 대한 명문의 규정이 없음에도 불구하고 判例가 등기의 추정력을 법률상의 추정으로 보면서 법률상의 권리추정, 법률상의 사실추정, 등기절차의 적법까지 추정하는 것은 문제가 있다는 견해가 있다.

IV. 사안의 검토
본인이 병에게 자신을 대리한 권한이 없다거나 병의 등기서류는 위조하였다는 등의 무효사유에 대한 증명책임을 지며 그 등기의 추정력을 번복할 만한 반대사실에 대한 증명책임이 있으나 사안의 경우 병에게 대리권이 수여되지 않았다는 사실에 대하여 법관이 확신을 갖지 못하였으므로 법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고해야 한다.
※문서문제에서의 문제제기 보너스 점수※

문서가 증거로 제출된 경우 그에 대한
증거조사절차로서 먼저 문서에 대한 성립의
인부절차를 진행, 이에 대한 상대방의 답변태도로서
자백, 침묵, 부인, 부지 등이 있는데 이에 대한
소송절차상의 취급이 각기 다르다.